



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003480/2021-22 (00012/2014) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 14/10/2021

Relator: Diretor Fernando Caio Galdi

Acusados:

Edemir Pinto

Manoel Felix Cintra Neto

Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo

Gustavo Henrique de Barros Franco

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo

René Mark Kern

Roberto Rodrigues

Ementa: Responsabilidade de membros do conselho de administração e de membro da diretoria da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, antiga BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por descumprimento de deveres fiduciários no exercício de suas atribuições, em violação aos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/1976. Advertência e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

(i) por maioria, pela **condenação** do Sr. Edemir Pinto, na qualidade de Diretor Geral da BM&F e posteriormente como Diretor Presidente da BM&FBovespa, a **penalidade de advertência** pelo descumprimento ao disposto no art. 154, caput, da Lei 6.404/1976, ao celebrar e executar aditamentos a contratos de outorga de opção de compra em condições diversas daquelas previstas no Plano BM&F, conforme aprovado em decisão assemblear.

(ii) por unanimidade, pela **absolvição** dos Srs. Manoel Felix Cintra Neto, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Gustavo Henrique de Barros Franco, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, René Mark Kern e Roberto Rodrigues, na qualidade de membros do conselho de administração, ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 pela ausência de elementos suficientes para caracterizar a atuação sem o devido cuidado e diligência exigidos na fiscalização da atuação do Diretor Presidente.

O Diretor Alexandre Rangel apresentou manifestação de voto onde acompanhou os fundamentos e as conclusões do voto do Diretor Relator com relação às ponderações referentes à prescrição e às absolvições dos membros do conselho de administração da Companhia. Entretanto, divergiu da condenação proposta a Edemir Pinto, votando pela absolvição do acusado.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presentes os advogados Nelson Eizirik e Marcus de Freitas Henriques, representando o acusado Edemir Pinto; Isabel Bocater e Luiza Rangel, representando aos acusados Manoel Felix Cintra Neto, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, René Mark Kern e Roberto Rodrigues; e Julia Damazio e Frederico Calmon da Gama, representando os acusados Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo e Gustavo Henrique de Barros Franco.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Fernando Caio Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flávia Perlingeiro.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 05/11/2021, às 10:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 05/11/2021, às 10:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 08/11/2021, às 15:21, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1367679** e o código CRC **CD8C499F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1367679** and the "Código CRC" **CD8C499F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº

19957.003480/2021-22

Reg. Col. 1056/18

Acusados:

Edemir Pinto
Manoel Felix Cintra Neto
Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo
Gustavo Henrique de Barros Franco
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
René Mark Kern
Roberto Rodrigues

Assunto:

Responsabilidade de membros do conselho de administração e de membro da diretoria da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, antiga BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por descumprimento de deveres fiduciários no exercício de suas atribuições, em violação aos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/1976.

Relator:

Diretor Fernando Caio Galdi

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”, em conjunto com SPS, a “Acusação”) junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para apurar a inobservância de deveres fiduciários de membros do conselho de administração e do diretor presidente, à época dos fatos, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”), antiga BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa” ou “Companhia”), pelas supostas irregularidades relacionadas à execução de planos de opção de compra de ações no âmbito da Companhia, no período de 2008 a 2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. O presente PAS originou-se de pedido de interrupção do prazo de assembleia geral extraordinária, que seria realizada em 27.03.12, apresentado por acionistas da Companhia, acompanhado de diversas reclamações, entre elas, as supostas irregularidades mencionadas acima.

3. Em 30.09.13, após a análise inicial das reclamações, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (“GEA-3”), subordinada à Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), propôs, no âmbito do Processo CVM RJ-2012-8535, a abertura de Inquérito Administrativo, conforme Relatório de Análise GEA-3/Nº 85/2013¹.

4. Em 04.12.13, o Superintendente Geral aprovou a referida proposta e, em 05.11.14, por intermédio da Portaria/CVM/SGE/Nº 271/2014², foi instaurado o presente Inquérito Administrativo, sob o nº 12/2014.

5. Como se verá a seguir, a Acusação concluiu, em breve síntese, que o então diretor geral da Companhia, Sr. Edemir Pinto, teria celebrado aditamentos a contratos de outorga de opções de compra com determinados administradores e, ainda, permitido que outros funcionários antecipassem o período de carência (*vesting*) dos respectivos contratos de opções de compra, em desacordo com o plano de opções de compra da Companhia, aprovado em assembleia geral extraordinária, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976. Diante deste cenário, a Acusação aponta que tais operações teriam gerado um prejuízo para a Companhia, no valor de R\$ 19,9 milhões.

6. Por fim, a Acusação também entende que os então membros do conselho de administração, os Srs. Manoel Felix Cintra Neto, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Gustavo Henrique de Barros Franco, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, René Mark Kern e Roberto Rodrigues, devem ser responsabilizados pela inobservância do seu dever de diligência por não terem fiscalizado e supervisionado as atividades desempenhadas pelo diretor geral da Companhia, relacionadas à execução do plano de opção de compra, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

¹ Doc. SEI 1244924, pág. 2.

² Doc. SEI 1244924, pág. 1.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. HISTÓRICO

7. As supostas irregularidades encontradas pela Acusação ocorreram no contexto do processo de “desmutualização” das bolsas de valores brasileiras, em 2007, por meio do qual as entidades administradoras de mercados regulamentados de valores mobiliários deixaram de ser associações sem fins lucrativos para se tornarem sociedades anônimas, inclusive com ações listadas em bolsa.

8. Até 2007, as conhecidas Bovespa e BM&F eram associações civis³, sem fins lucrativos, regidas por seus respectivos estatutos sociais, com autonomia financeira, administrativa e patrimonial, cujos patrimônios eram representados por títulos que pertenciam às sociedades corretoras.

9. Com o objetivo de implementar a “desmutualização” das bolsas, tais associações realizaram diversas operações societárias que culminaram com a criação da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sociedade anônima de capital aberto.

10. Como uma das etapas deste processo, em 20.09.07, a assembleia geral extraordinária da Bolsa de Mercadorias e Futuro - BM&F S.A. (“BM&F”) aprovou, entre outras matérias correlatas, a incorporação, pela BM&F, de parcela cindida da BM&F Associação.

11. Na mesma assembleia, os acionistas também aprovaram o Plano de Opções de Compra da BM&F (“Plano BM&F”), cujo objetivo era *“permitir que administradores, empregados e prestadores de serviço da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, sujeito a determinadas condições, adquiram ações da Companhia”*⁴.

12. Nos termos da Cláusula 3.1, a competência da administração do Plano BM&F era do conselho de administração, o qual poderia delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, à Comissão de Indicação e Remuneração da Companhia.

13. Em 23.10.07, o conselho de administração da BM&F aprovou os parâmetros e diretrizes do Plano BM&F, entre os quais, as orientações sobre o prazo de exercício e limites a serem observados, bem como deliberou ***“ratificar a autorização já concedida ao DG [Diretor Geral da BM&F] para executar o plano dentro das premissas***

³ Bolsa de Valores de São Paulo e BM&F Associação.

⁴ Doc. SEI 1244940, pág. 531.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

anteriormente aprovadas, bem como efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos nas condições por ele estabelecidas, mediante assinatura dos contratos de outorga de opções com os beneficiários”⁵. Portanto, houve a delegação da competência para a execução do Plano BM&F para o diretor geral da BM&F S.A., Sr. Edemir Pinto, cuja fiscalização seria de competência do conselho de administração.

14. Em seguida, ainda no contexto da implementação da organização societária, em 08.05.08, a assembleia geral extraordinária da Nova Bolsa S.A. (“Nova Bolsa”) aprovou, entre outras matérias correlatas, o protocolo de incorporação da BM&F pela Nova Bolsa⁶, a qual representou uma das etapas da reorganização societária para a criação da BM&FBovespa (atualmente, B3).

15. Na mesma assembleia, os acionistas também aprovaram:

(a) a sucessão “dos contratos de opção celebrados entre a BM&F e os beneficiários do Plano BM&F, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da BM&F de 20.09.2007, cujos termos e condições são ora ratificados, nos mesmos termos e condições contratados com cada um dos beneficiários que celebraram com a BM&F Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, (...), aprovando-se, em consequência, a substituição de todas as opções de compra de ações objeto de tais contratos com os beneficiários da BM&F, representando a possível emissão de até 19.226.391 (dezenove milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e uma) ações ordinárias da Companhia, por opções de compra da Nova Bolsa, nos mesmos termos e condições do Plano BM&F, bem como o novo Plano de Opção de Ações da Companhia (....)”⁷ (grifei); e

⁵ Doc. SEI 1245011, pág. 2071.

⁶ Da mesma forma, em 08.05.08, a assembleia geral extraordinária da Bovespa Holding S.A. (“Bovespa Holding”), também aprovou, entre outras matérias correlatas, o protocolo de incorporação de ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa.

⁷ O Plano de Opção de Compra de Ações da BM&FBovespa estabelece, em seu item 14, o seguinte: “14. Recepção do Plano BM&F. 14.1. A Companhia incorporou a Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F S.A. (“BM&F”) e este Plano recebe o Plano de Opção de compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da BM&F de 20 de setembro de 2007 (“Plano BM&F”), bem como as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração da BM&F sobre a forma de execução do Plano BM&F e os atos do Diretor Geral da BM&F que permitem a outorga e emissão de um saldo de até 19.226.391 ações ordinárias, cujos termos e condições são ratificados, tudo conforme contratos de opção de compra de ações celebrados com os respectivos beneficiários (“Contratos”) arquivados na sede da Companhia. (...) 14.3. Por serem decorrentes do Plano BM&F, as condições dos Contratos são neste ato ratificados, não obstante o fato de eventualmente não estarem em conformidade com os termos e condições das novas opções a serem outorgadas com base neste Plano, ressalvado que as disposições do Plano BM&F e dos Contratos que fazem referência às facilidades que seriam aplicáveis após a outorga ou exercício das opções, ao Conselho de Administração e ao Diretor Geral da BM&F, competirão respectivamente ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(b) que “as disposições do Plano BM&F e dos Contratos que fazem referência às facilidades que seriam aplicáveis após a outorga ou exercício das opções, ao Conselho de Administração e ao Diretor Geral da BM&F, competirão respectivamente ao Conselho de Administração e ao Diretor Presidente da Companhia, nos mesmos termos originais do Plano BM&F”⁸ (grifei).

16. Assim, a decisão assemblear atribuiu a administração do Plano BM&F ao diretor presidente da BM&FBovespa, cargo ocupado pela mesma pessoa, Sr. Edemir Pinto. Os termos e condições do Plano BM&F continuaram válidos após a incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, cujos direitos e obrigações foram integralmente sucedidos pela BM&FBovespa.

III. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº 12/2014

17. Poucos anos após o encerramento do processo de “desmutualização”, em 17.02.12, a BM&FBovespa convocou assembleias gerais ordinária e extraordinária⁹, a serem realizadas em 27.03.12, com as seguintes ordens do dia:

(I) AGO

- (i) aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2011;
- (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2011; e
- (iii) fixação da remuneração dos administradores para o exercício social de 2012.

(II) AGE: deliberação sobre a seguinte reforma estatutária:

- (i) alteração do artigo que estabelece o número de ações em que se divide o capital social, para refletir o cancelamento de ações aprovado pelo conselho de administração em 13.12.11¹⁰;

Conselho de Administração e ao Diretor Presidente da Companhia, nos mesmos termos originais do Plano BM&F” (doc. SEI 1245011, pág. 78-79).

⁸ Doc. SEI 1245011, pág. 2074.

⁹ Doc. SEI 1244924, pág. 115.

¹⁰ Em 13.12.11, o conselho de administração da Companhia deliberou cancelar 64.014.295 ações ordinárias, e, como consequência, o capital social, antes representado por 2.044.014.295 ações ordinárias, passou a ser dividido em 1.980.000.000 ações ordinárias.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) adequação do comitê de auditoria à Instrução CVM nº 509/11;
- (iii) alterações em artigos que disciplinam ofertas públicas de aquisição de ações de emissão da BM&F; e
- (iv) inclusão de previsão expressa de aplicação do Regulamento do Novo Mercado quando a assembleia precisar solucionar casos omissos no estatuto social.

18. A AGO foi realizada na data prevista e todas as matérias da ordem do dia foram aprovadas por maioria. No entanto, não houve quórum suficiente para instalar a AGE.

19. Desta forma, em 28.03.12, a BM&F publicou a segunda convocação da AGE, a ser realizada em 10.04.12, com a mesma ordem do dia.

20. Em 04.04.12, F.F.B.H. e T.CTVM (em conjunto, os “Reclamantes”) protocolaram pedido de interrupção do prazo de antecedência da segunda convocação de assembleia geral extraordinária da BM&F (“Pedido de Interrupção do Prazo da AGE”), acompanhado de diversas denúncias de irregularidades supostamente cometidas pelos administradores da BM&F, cujos principais termos estão resumidos abaixo:

(I) Fundamentos para o Pedido de Interrupção do Prazo da AGE:

21. Para fundamentar o Pedido de Interrupção do Prazo da AGE, os Reclamantes apresentaram, em resumo, as seguintes principais alegações:

- (i) Alteração no número de ações do capital social: a alteração do número de ações emitidas pela Companhia, em razão (a) do cancelamento de ações aprovado em reunião do conselho de administração, (b) da alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício das opções de compra do Plano BM&F e (c) de eventual recompra no âmbito do plano de recompra da Companhia, poderia comprometer (a.1) o saldo líquido remanescente de dividendos a serem recebidos pelos acionistas e (b.1) “os limites de participação indireta no patrimônio líquido ou no capital social com direito a voto da BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados, o que depende de prévia autorização da CVM”¹¹. De acordo com a reclamação, a limitação sobre as participações indiretas na BM&FBovespa

¹¹ Doc. SEI 1244924, pág. 2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deveria ser estabelecida antes da AGE, por meio de manifestação do Colegiado da CVM¹²;

(ii) Falta de Disclosure de Ações Judiciais: a BM&FBovespa não divulgou, antes ou durante a realização da AGE, a decisão desfavorável de primeira instância, proferida pela 22ª Vara do Distrito Federal, em 13.02.2012, em relação ao ressarcimento aos cofres públicos, no âmbito de determinadas ações populares e civis públicas de improbidade administrativa (“Ações Judiciais”)¹³;

(II) Outras Irregularidades: exigência de provisão referente às Ações Judiciais:

(i) a BM&FBovespa não provisionou adequadamente os valores referentes às Ações Judiciais em suas demonstrações financeiras, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC nº 25;

(ii) em razão das sentenças judiciais condenatórias proferidas pelo Juízo da 22ª Vara do Distrito Federal, não seria razoável considerar a afirmação de existir “risco remoto de perda”, conforme mencionado no comunicado ao mercado divulgado em 27.03.2012;

(iii) ainda que não se reconheça o provisionamento de acordo com a norma contábil mencionada acima, “há que se cogitar de reconhecimento de passivo contingente, (...), ou seja, em ambos os casos sendo reclamado o refazimento das demonstrações financeiras”¹⁴; e

(iv) o procedimento adotado pela BM&F “colide frontalmente com a orientação dada aos diretores de relações com investidores e aos auditores independentes, no item IV, do Ofício/Circular/CVM/SNC/SEP/Nº 002/2011”¹⁵.

¹² Nesse sentido, os Reclamantes alegaram o seguinte: “Requer-se que, na data de publicação do anúncio de convocação da AGE, a BM&FBovespa forneça a posição dos acionistas alcançados pelo plano de recompra de ações da Companhia e pelo plano de opção de compra de ações da Companhia, (...) que será tomada como base de cálculo das posições acionárias para o referido pagamento de dividendos” (doc. SEI 1244924, pág. 3).

¹³ De acordo com os Reclamantes, o comunicado ao mercado somente foi divulgado após o encerramento da AGE. Portanto, houve “flagrante descumprimento do dever de ampla divulgação e imediata disseminação de fatos relevantes que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado” (doc. SEI 1244924, pág. 3).

¹⁴ Doc. SEI 1244924, pág. 9.

¹⁵ Doc. SEI 1244924, pág. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. Em reunião realizada em 09.04.2012, o Colegiado indeferiu o Pedido de Interrupção do Prazo da AGE¹⁶.

23. Considerando o indeferimento do Pedido de Interrupção de Prazo da AGE, em 24.04.2012, os Reclamantes protocolaram pedido de reconsideração, de acordo com o qual, além de reafirmarem as reclamações originais, também apresentaram outras reclamações referentes ao Plano BM&F.

24. Em 29.05.2012, o Colegiado deliberou não conhecer o pedido de reconsideração¹⁷. No entanto, ressaltou que *“todas as demais questões levantadas pelos Interessados serão objeto de análise pelas áreas cuja área de atenção seja afeta aos indícios de irregularidade a serem apurados”*¹⁸.

25. Nesse sentido, a GEA-3 analisou, por meio do RA/CVM/SEP/GEA-3/Nº85/13¹⁹, as reclamações apresentadas e entendeu que havia elementos que justificariam o

¹⁶ De acordo com a ata da reunião do Colegiado realizada em 09.04.2012, *“os Requerentes pretendem rediscutir a legalidade do cancelamento de ações, quando na verdade a questão a ser deliberada em assembleia é apenas a adequação da redação do estatuto ao cancelamento que já foi deliberado. Para a SEP, o cancelamento ocorreu por deliberação do conselho de administração, sendo, portanto, um ato jurídico perfeito e eficaz desde o arquivamento na junta comercial da ata da reunião do conselho realizada na data da assembleia. Considerando que a AGE irá deliberar apenas sobre a reforma estatutária, não se faz necessária, no entendimento da SEP, a disponibilização das informações solicitadas pelos Requerentes sobre planos de recompra de ações e stock options”* (doc. SEI 1244924, pág. 188).

¹⁷ De acordo com a ata da Reunião do Colegiado, *“o Relator Roberto Tadeu observou que a AGE foi realizada em 10.04.2012, de maneira que o presente pedido de reconsideração perdeu o seu objeto. De fato, ainda que o pedido de reconsideração tivesse mérito (o que só se admitiu para fins argumentativos), não seria possível interromper o prazo de antecedência de convocação de assembleia já ocorrida. O Relator entendeu, portanto, que o pedido de reconsideração não deveria ser conhecido por faltar aos Interessados o indispensável interesse de agir. Não obstante, o Relator analisou cada argumento apresentado pelos Interessados e ressaltou que, ao contrário do alegado no pedido de reconsideração, a decisão atacada não apresentou quaisquer erros, contradições, omissão ou obscuridade. (...) Com relação à alegação de erros na decisão, o Relator lembrou que a AGE foi convocada para fins de deliberar sobre alterações no Estatuto Social da BM&FBovespa, dentre as quais se destaca aquela destinada a adequar o art. 5º à nova quantidade de ações de emissão da companhia, decorrente do cancelamento de 64.014.295 ações mantidas em tesouraria, sem redução do seu capital social. Assim, as propostas que seriam submetidas à AGE não aparentavam apresentar nenhuma irregularidade que justificasse a interrupção pleiteada, porquanto circunscritas à adequação do Estatuto Social da companhia a deliberações já tomadas. Com relação ao pedido para que o Colegiado determinasse a republicação das demonstrações financeiras da BM&FBovespa, o Relator entende que se insere na análise das irregularidades alegadas pelos Interessados, devendo, com isso, ser objeto de apreciação pela área técnica afeta à matéria. Ainda que assim não fosse, a Deliberação CVM 388/01 dispõe que compete à SEP determinar o refazimento e/ou republicação de demonstrações financeiras, precedida da concordância da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, nos aspectos relacionados a práticas e procedimentos contábeis”* (http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2012/20120529_R1.html).

¹⁸ Doc. SEI 1245011, pág. 2068.

¹⁹ Doc. SEI 1244924.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prosseguimento das análises ou a formulação de acusação em relação aos seguintes assuntos relacionados ao Plano BM&F: **(a)** suposta antecipação de períodos de carência do exercício de opções de compra do Plano BM&F e **(b)** suposta outorga de opções de compra a prestadores de serviços terceirizados, à revelia do estatuto social e do Plano BM&F.

26. Considerando a extensão das diligências necessárias para o esclarecimento de tais fatos, em 30.09.13, a SEP, no âmbito do Processo CVM RJ-2012-8535, propôs abertura de Inquérito Administrativo, conforme Relatório de Análise GEA-3/Nº 85/2013.

27. Em 04.12.13, o Superintendente Geral aprovou a referida proposta e, em 05.11.14, por intermédio da PORTARIA/ CVM/SGE/Nº 271/2014, foi instaurado o presente Inquérito Administrativo, sob o nº 12/2014.

IV. ACUSAÇÃO

28. Inicialmente, a Acusação descreve o histórico de aprovações e o contexto no qual estavam inseridas as deliberações sobre o Plano BM&F.

29. Em seguida, a Acusação elenca as seguintes situações que, após a análise das reclamações, chamaram a atenção da área técnica no Relatório de Análise GEA-3/Nº 85/2013:

- (i) alguns diretores renunciaram aos cargos estatutários e, em seguida, foram demitidos sem justa causa pela Companhia e, ainda assim, fizeram jus ao exercício antecipado de opções do Plano BM&F (“Antecipação dos Prazos de Carência”);
- (ii) houve contratação de ex-administradores da Companhia como prestadores de serviço de consultoria após as suas demissões sem justa causa pela BM&F (“Contratação de Ex-funcionários”); e
- (iii) houve descumprimento de valores e prazos do pagamento previstos nos respectivos contratos de prestação de serviços (“Consultoria” e, em conjunto com Contratação de Ex-funcionários, “Prestação de Serviços”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

30. Após a apuração dos fatos, a Acusação concluiu que não havia elementos suficientes de autoria e materialidade para oferecer acusação em relação à Prestação de Serviços (itens “ii” e “iii”, acima)²⁰.

31. No entanto, após a conclusão da investigação, a Acusação concluiu que houve irregularidades, especificamente, em relação a duas situações: (i) antecipação do *vesting* por determinados administradores, em desacordo com os termos e condições do Plano BM&F e (ii) celebração de aditamentos aos contratos de outorga opções de compra, também em desacordo com os termos e condições do Plano BM&F.

32. Tais situações estão relatadas abaixo.

Antecipação dos Prazos de Carência

33. As hipóteses de desligamento da Companhia e as suas consequências em relação ao Plano BM&F estão descritas em seu Item 8²¹, cuja redação está copiada abaixo:

“8. Hipóteses de Desligamento da Companhia e seus Efeitos. 8.1. Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto no item 8.2, abaixo.

8.2. Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário:

(a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, rescindindo o seu contrato de prestação de serviços, ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo decisão em contrário do Conselho de Administração; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data de desligamento, poderão ser exercidos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização;

(b) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços por justa causa ou destituição do seu cargo por violar

²⁰ Por conta disso, me aterei somente aos fatos objeto de acusação.

²¹ Doc. SEI 1245011, pág. 2075.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

os deveres e atribuições de administrador, todos os direitos já exercíveis ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização;

(c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços sem justa causa ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, poderão ser exercidos, desde que o Beneficiário o faça no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de seu desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização”.

34. A Acusação explica que analisou 72 casos de beneficiários, cujos prazos de carência foram antecipados e em todos, exceto um²², a justificativa para a antecipação foi a dispensa por iniciativa da BM&F sem justa causa.

35. Entre tais beneficiários, a Acusação identificou os seguintes quatro administradores que renunciaram aos seus cargos de diretores estatutários poucos dias antes de suas demissões sem justa causa pela BM&F: (i) A. C. F., (ii) M. A. T., (iii) O. Y. e (iv) R. M. M..

36. Nesse sentido, a Acusação explica que “nos quatros casos identificados, os direitos ainda não exercíveis não foram automaticamente extintos e foram antecipados”²³. Para a Acusação, “a demissão sem justa causa seria a única hipótese

²² Sobre a exceção, a Acusação descreveu o seguinte: “O caso destoante foi o de [M. A. F.], analista de desenvolvimento de sistemas, o qual pediu demissão do seu emprego (CD fl. 1.617, CAGED de 12.2008), e por esta razão, enquadrar-se-ia no item 8.2., (a), do Plano BM&F: “(i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão [restariam] automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo decisão em contrário do Conselho de Administração”. Entretanto, seus direitos ainda não exercíveis não foram extintos, conforme determina o Plano BM&F, e além de não terem sido extintos, foram antecipados (fls. 883 a 911), sem que tivesse havido a referida “decisão em contrário do CA”. Sobre isso, a Companhia informou que “constatou-se a existência de caso isolado em 01.12.08, com o exercício antecipado do direito à subscrição de 9.000 ações, quando do pedido de demissão do funcionário [M. A. F.], ações essas correspondentes a 0,03% do total de ações cuja emissão havia sido autorizada pelo Conselho de Administração na reunião de 23.10.07” (doc. SEI 1245011, pág. 2076).

No entanto, tal caso não foi objeto da presente acusação.

²³ Doc. SEI 1245011, pág. 2076.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prevista no Plano BM&F para que fizessem jus à não extinção e ao exercício antecipado das opções sem a necessidade de análise pelo Conselho de Administração, o que de fato não ocorreu”²⁴.

37. Em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 175/2013, a Companhia informou que *“todos os diretores da BM&F S.A. – Bolsa de Mercadorias e Futuros e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sem exceção, mantinham vínculo empregatício com a Bolsa, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e suspenso na forma da Súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho”* e que *“após terem renunciado a seus cargos estatutários, encerrando assim o período de suspensão do contrato de trabalho, tais diretores permaneceram vinculados à BM&FBOVESPA com base em tais contratos de trabalho. A renúncia apresentada por esses diretores não produziu o efeito de desligá-los da BM&FBOVESPA, tendo em vista a subsistência de seu vínculo empregatício após terem deixado seus respectivos cargos estatutários”²⁵.*

38. No entanto, após os esclarecimentos prestados pela Companhia sobre a antecipação do exercício das opções dos quatro administradores, a Acusação entendeu que a Companhia não conseguiu explicar *“quais foram as atribuições específicas, na qualidade de empregados, sujeitos ao regime da CLT, exercidas após suas renúncias, como dá a entender a manifestação da Companhia e de seus administradores. Além disso, os prazos entre os efeitos das renúncias e as respectivas demissões foram muito curtos”²⁶.*

39. Ainda, como forma de calcular eventual prejuízo gerado com o exercício das opções, a Acusação apresentou uma tabela com informações detalhadas²⁷ sobre as quantidades das opções outorgadas, datas de outorga, renúncia e dispensas pela Companhia, bem como preços de mercado das ações nas datas de exercício.

²⁴ Doc. SEI 1245011, pág. 2076.

²⁵ Em relação a quais cargos em regime CLT os administradores teriam voltado a ocupar após as respectivas renúncias, a Companhia informou que, no que diz respeito a A.C.F., M.A.T., e R.M.M., que *“não ocuparam cargos em regime CLT, não estatutários, após a sua renúncia aos cargos estatutários”*. Em relação a O.Y., a Companhia informou que *“permaneceu, para fins exclusivos do regime da CLT, na função de Diretor de auto-regulação”* e que *“o período entre a renúncia do Sr. O.Y. do cargo estatutário e seu efetivo desligamento como funcionário, em 08/12/2008, teve como intuito permitir que o Sr. O.Y. auxiliasse na transição para o novo Diretor de auto-regulação estatutário, o Sr. L.G.M.M.”* (doc. SEI 1245011, pág. 2078).

²⁶ Doc. SEI 1245011, pág. 2080.

²⁷ Doc. SEI 1245011, pág. 2077.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. Diante deste cenário, além de os exercícios estarem em desacordo com o disposto no Plano BM&F, a Acusação entendeu que as quantidades antecipadas das opções outorgadas acarretaram um custo para a Companhia no valor de R\$ 19.901.020,00, sem que houvesse autorização do conselho de administração para esse tipo de despesa.

41. Portanto, na visão da Acusação, o Sr. Edemir Pinto, diretor presidente à época dos fatos, deixou de exercer suas atribuições, no intuito de lograr os fins e os interesses da Companhia, em infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/1976, ao não ter extinguido o direito ao exercício das opções desses quatro administradores, em razão das injustificadas demissões, ou não ter submetido o assunto à deliberação do conselho de administração.

Celebração de Aditamentos

42. Previamente à conclusão do processo de “desmutualização”, em 30.04.2008, a BM&F celebrou aditamentos aos contratos de outorga de opções de compra de ações do Plano BM&F com seis beneficiários²⁸ (“Aditamentos”), por meio dos quais lhes foram outorgados lotes adicionais de opções (“Opções Adicionais”).

43. Os Aditamentos estabeleceram as seguintes alterações: (a) a data de 02.01.2010 como início do prazo para exercício das Opções Adicionais, (b) a impossibilidade de antecipação dos prazos de exercícios das Opções Adicionais, inclusive na hipótese de desligamento por vontade da Companhia e (c) o beneficiário teria o prazo de 180 dias, a contar de 02.01.2010, para exercer as Opções Adicionais.

44. Na visão da Acusação, as disposições previstas nos itens acima, estariam em desacordo com a regra prevista no Item 8.2, letra (c), do Plano BM&F²⁹, e, portanto, o diretor geral da BM&F, Sr. Edemir Pinto, não poderia ter celebrado os Aditamentos com tais regras.

²⁸ A.C.F., J.C.B., M.A.T., N.L.C., C.E.S.L., e L.G.M.M.

²⁹ Para melhor referência, cito novamente o item 8.2, letra (c): “**Item 8.2:** Se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o Beneficiário: (...) (c): for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços sem justa causa ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência; e (ii) os direitos já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, poderão ser exercidos, desde que o Beneficiário o faça no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de seu desligamento, após o que tais direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

45. Além disso, a Acusação explica que A.C.F., J.C.B., M.A.T. e N.L.C. foram demitidos sem justa causa em 07.07.2008 e exerceram as Opções Adicionais em 19.01.2010, 18.02.2010, 05.03.2010 e 04.02.2010, respectivamente. C.E.S.L. e L.G.M.M., por sua vez, foram demitidos sem justa causa em 14.08.2008 e exerceram as Opções Adicionais somente em 23.02.2010 e 27.04.2010, respectivamente. Isto é, nos seis casos, as Opções Adicionais observaram o prazo estabelecido nos Aditamentos e não no Plano BM&F.

46. Portanto, de acordo com a Acusação, Sr. Edemir Pinto, diretor geral à época dos fatos, atuou em desconformidade com as regras do Plano BM&F, concedendo prazos diferentes do estabelecido para o exercício das Opções Adicionais, deixando de exercer suas atribuições, no intuito de lograr os fins e os interesses da Companhia, em infração ao caput do art. 154 da Lei nº 6.404/1976.

A Conduta do Conselho de Administração na Fiscalização do Plano BM&F

47. De acordo com a Acusação, a delegação da implementação do Plano BM&F ao diretor geral, Sr. Edemir Pinto, não tinha o condão de afastar a responsabilidade do conselho de administração na fiscalização da atuação do delegatário.

48. Nesse sentido, a Acusação entende que, diante das irregularidades encontradas, “*é certo que os membros do CA deveriam ter fiscalizado o delegatário para assegurar a obediência ao Plano BM&F. Com efeito, deveriam ter sido respeitadas as condições pré-aprovadas por decisão assemblear, as quais deveriam ter sido as únicas a nortear o exercício de direitos dos beneficiários, sob pena de desvirtuar e desnaturar as regras até então vigentes constantes do plano da extinta BM&F*”³⁰.

49. Além disso, a Acusação menciona que os acusados não implementaram controles específicos para fiscalizar a execução do Plano BM&F e “*mesmo sendo, em alguns casos, dada ciência direta e inequívoca ao CA da ocorrência de irregularidades, também não houve atuação de seus membros no sentido de corrigir as falhas e melhorar os controles*”³¹ ³².

³⁰ Doc. SEI 1245011, p. 2084-2085.

³¹ Doc. SEI 1245011, pág. 2085.

³² Para fundamentar este argumento, a Acusação cita as seguintes respostas enviadas pelos membros do conselho de administração em razão do recebimento de ofícios da área técnica: “*A execução do Plano de Opções da BM&F S.A. submeteu-se aos mecanismos habituais de controle utilizados pelo Conselho de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

50. Portanto, de acordo com a Acusação, muito embora o conselho de administração tenha definido Sr. Edemir Pinto como o administrador do Plano BM&F, (a) não houve (i) esforço específico na atividade de administração do Plano BM&F, e (ii) supervisão em relação às competências delegadas ao diretor presidente e (b) não foram implementados mecanismos de controle específico para a fiscalização do Plano BM&F.

Conclusão

51. Considerando os fatos relatados acima, a Acusação concluiu o seguinte:

(a) Edemir Pinto, diretor presidente à época dos fatos, deixou de exercer devidamente suas atribuições, no intuito de lograr os fins e os interesses da Companhia, ao (i) não reconhecer a extinção dos direitos ainda não exercíveis dos ex-diretores que renunciaram, autorizando pagamentos no valor de R\$ 19.901.020,00 sem submeter o assunto ao conselho de administração (ii) ao estabelecer, nos Aditamentos, regras diferentes das constantes do Plano BM&F sem que fosse implementada alteração no Plano BM&F e dada a devida ciência aos acionistas. Portanto, deve ser responsabilizado pelo descumprimento do art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; e

(b) Os membros do conselho de administração Manoel Felix Cintra Neto, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Gustavo Henrique de Barros Franco, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, René Marc Kern e Roberto Rodrigues não empregaram o cuidado e a diligência necessários na administração do Plano BM&F e na fiscalização da respectiva delegação concedida, mesmo após tomarem

Administração, no exercício de seus deveres de orientação geral dos negócios da Companhia e de fiscalização da gestão da diretoria, dentre os quais destaco: (i) as auditorias interna e externa, essa última realizada por parte independente, que continuamente elaboraram análises, recomendações e comentários objetivos acerca das atividades examinadas; (ii) as demonstrações financeiras e balanços auditados, aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia de Acionistas, que refletem os rígidos controles financeiros estabelecidos pela própria CVM, seja por meio de suas instruções ou da adoção dos Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; (iii) o relatório da administração, por meio do qual são levadas ao Conselho de Administração, em documento consolidado, as iniciativas e atividades desenvolvidas pela administração; e (iv) os comitês internos vinculados ao Conselho de Administração, tais como a comissão de indicação e remuneração e o comitê de auditoria, que reforçavam a constante avaliação das atividades da administração.” (doc. SEI 1245011, pág. 2086); (...)

“A execução do Plano de Opções da BM&F S.A. ficava a cargo da administração da companhia, de modo que atividades como verificação de contratos de outorga e requisitos, bem como a operacionalização de processos de pagamento, eram conduzidas de forma habitual pelas áreas da companhia responsáveis pela gestão de recursos humanos ou pelo departamento financeiro, conforme o caso, sempre sob supervisão e em linha com diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração.” (doc. SEI 1245011, pág. 2086).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ciência do pagamento de direitos que deveriam ter sido extintos. Violaram, portanto, o dever de diligência prescrito no art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

V. RAZÕES DE DEFESA

52. Os Acusados foram devidamente intimados e apresentaram suas razões de defesa.

Razões de defesa conjunta de Gustavo Henrique de Barroso Franco e Júlio de Siqueira Araújo

53. Antes de relatar os argumentos de mérito, apresentarei as preliminares suscitadas pelos acusados.

Preliminares

Inépcia da Acusação

54. Inicialmente, os acusados alegam a inépcia da acusação, já que, na visão da defesa, a acusação seria “*vaga, genérica e sem a devida apuração e comprovação das alegações em atitude que, além de contrariar indiscutíveis princípios de direito, embaraça a elaboração desta defesa*”³³.

55. Neste sentido, os acusados sustentam que a acusação teria sido feita quase dez anos após a ocorrência dos fatos, o que teria gerado dificuldades para reunir documentos e representaria uma inversão do ônus da prova, assim como uma afronta ao princípio da ampla defesa.

56. Além disso, a defesa argumenta que a acusação presume uma violação ao art. 153 da Lei nº 6.404/76 simplesmente porque teria ocorrido um ato ilícito por parte do diretor presidente da Companhia.

57. Desta forma, também não teriam sido apresentados elementos mínimos de materialidade e autoria que legitimariam o processo administrativo sancionador. Assim, a defesa alega que apenas teriam sido acusados “*conselheiros de administração que exerceram cargos e que estavam presentes na reunião da BM&F quando da aprovação do Plano BM&F e que permaneceram no conselho da B3 até a época dos fatos e que tenham participado das reuniões sub-judice*”³⁴, sendo que “*eventual inexistência de*

³³ Doc. SEI 1245042, pág. 2192.

³⁴ Doc. SEI 1245042, pág. 2193.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

controles internos e efetivo monitoramento seria de responsabilidade de todo o conselho e não apenas de alguns membros”³⁵.

Prescrição Quinquenal

58. Os acusados alegam a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 1º, da Lei nº 9.873/1999, tendo em vista que se passaram mais de oito anos entre o fato mais recente referido pela Acusação (2 de fevereiro de 2009) e a intimação dos acusados (janeiro de 2018), momento que teria o condão de interromper a prescrição.

59. Além disso, a defesa sustenta que não houve a configuração de qualquer evento interruptivo da prescrição neste período, tendo em vista que *“para a interrupção da prescrição dessa pretensão, é preciso não só um ato voltado para o seu exercício, mas também que tal ato se dirija ao respectivo administrado. Em outras palavras, exige-se aqui a prática de um ato receptício, do qual o sujeito passivo tenha pleno conhecimento”³⁶.*

Mérito

Limites à Fiscalização dos Diretores pelo Conselho de Administração

60. De acordo com a defesa, há limites à função de fiscalização dos membros do conselho de administração. Nessa linha, sustentam que apesar da importância e abrangência da função fiscalizatória de tais administradores, *“seria desarrazoado esperar que um órgão que atua por meio de reuniões periódicas, se envolvesse em toda e qualquer decisão tomada ou ato praticado pelos diretores”³⁷.*

61. Ainda, os acusados argumentam que a fiscalização realizada pelos membros do conselho de administração não envolve análises específicas das operações e negócios rotineiros, a menos que apresentem “sinais de alerta” que justificariam a atuação investigativa.

62. No presente caso, a defesa entende que a função de fiscalização e supervisão da implementação do Plano BM&F envolveria apenas a verificação do cumprimento de seus objetivos, no sentido de (a) alinhar os interesses entre administradores, empregados e acionistas, (b) obter bom desempenho da Companhia, e (c) ter coerência com a política

³⁵ Doc. SEI 1245042, pág. 2193.

³⁶ Doc. SEI 1245042, pág. 2195.

³⁷ Doc. SEI 1245042, pág. 2196.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de remuneração. Isto é, as atividades desempenhadas pelos conselheiros envolveriam apenas o monitoramento estratégico e finalístico da execução do Plano BM&F, com o acompanhamento atento aos “sinais de alerta”.

63. Por fim, a defesa alega que não foram soados quaisquer “sinais de alerta”, seja por meio dos relatórios anuais de auditoria ou pelas atividades desempenhadas pelos comitês de auditoria e de indicações e remuneração.

Inexistência de Descumprimento ao Dever de Diligência

64. A defesa também sustenta que não teria havido violação ao dever de diligência. Segundo os acusados, à época dos fatos, a doutrina entendia que os deveres dos conselheiros estavam voltados para o monitoramento do andamento dos negócios sociais de forma estratégica e eficiente, sem ser necessário supervisionar medidas rotineiras da companhia³⁸. Neste sentido, argumentam que, ainda que a conduta dos acusados fosse baseada na estruturação e manutenção de sistemas de controles internos satisfatórios, os membros do conselho de administração não teriam demonstrado falhas que permitissem os supostos desvios na execução do Plano BM&F.

Estrutura de Controles Internos e Regra da Decisão Negocial

65. Os acusados alegam que tanto as decisões negociais quanto as decisões organizacionais tomadas pelos administradores são protegidas pelo princípio da *business judgment rule*.

66. Nesse sentido, a defesa argumenta que a CVM, “*exceção feita aos controles internos relacionados com a elaboração das demonstrações contábeis*”³⁹, não poderia entrar no mérito da decisão dos administradores a respeito da definição dos contornos da estrutura de controles da Companhia, já que se trata de uma decisão organizacional dos administradores.

67. Nessa linha, a defesa entende que a definição da estrutura de controles internos da companhia “*deve, necessariamente, perpassar uma análise de riscos, custos e benefícios em função do porte, especificidades e nível de complexidade de cada organização – razão*

³⁸ Assim, a defesa entende que “o dever de diligência dos conselheiros comporta avaliação à luz de suas funções no ambiente de governança e das circunstâncias de sua atuação; nunca deve ser examinado com mero desdobraimento ou consequência de ilícitos praticados por diretores em atos de gestão, sob pena de, toda vez que caracterizada uma irregularidade diretiva, haver necessária punição do conselho” (doc. SEI 1245042, pág. 2207).

³⁹ Doc. SEI 1245042, pág. 2212.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pela qual a decisão a seu respeito deve ser analisada com muita prudência pelo regulador”⁴⁰.

68. Ainda, asseveram que o conselho de administração teria instaurado um comitê de auditoria e contratado consultorias externas para incrementar a governança e os controles internos, sendo que a análise de tais órgãos jamais teria indicado a existência de “sinais de alerta” que demandassem investigações.

Falta de Clareza quanto à Ocorrência de Irregularidades

69. A defesa alega que haveria falta de clareza quanto à ocorrência das supostas irregularidades, tendo em vista que:

- (a) a antecipação do *vesting* dos executivos estaria em linha com o disposto no item 8.2(c)(i) do Plano BM&F, bem como havia sido determinada no protocolo de incorporação da BM&F aprovada em assembleia geral, de modo que teria sido a melhor decisão negocial de acordo com os interesses da Companhia diante do potencial risco trabalhista na época, além do fato de o Conselho de Administração ter o poder de autorizar a manutenção das opções dos executivos; e
- (b) os aditamentos aos contratos de opção de compra buscaram o melhor interesse da Companhia, pois o Plano BM&F autorizava a celebração de contratos adicionais com condições diferenciadas, desde que observassem seus termos.

Inexistência de Orientação sobre a Gestão de Planos de Remuneração Baseada em Ações

70. Os acusados alegam a ausência de orientações da CVM sobre a gestão de planos de remuneração baseada em ações e a respeito da extensão do monitoramento esperado pelo conselho de administração. Neste sentido, argumentam que a Lei nº 6.404/1976, “*ao admitir a outorga de opções de aquisição de ações, em seu art. 168, § 3º, limita-se a arrolar os beneficiários de tais outorgas (...), e a estabelecer a necessidade de previsão estatutária (para aumento de capital autorizado e a outorga de opção de compra) e de aprovação do plano em assembleia geral*”⁴¹.

71. Além disso, os acusados sustentaram que, à época dos fatos investigados, esta CVM também não exigiria informações sobre tal tema, tampouco especificaria quais documentos e informações deveriam ser apresentados aos acionistas da Companhia por

⁴⁰ Doc. SEI 1245042, pág. 2213.

⁴¹ Doc. SEI 1245042, pág. 2223.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ocasião da assembleia geral convocada para deliberar a respeito da aprovação de planos de remuneração⁴².

Vedação à Aplicação Retroativa de Nova Interpretação

72. De acordo com a defesa, “[v]ez que é cediço o entendimento da CVM de que não cabe ao conselheiro desempenhar o seu dever de monitorar identificando falhas pontuais, mas estruturando controles internos capazes de identificar falhas materiais, sem impor custos excessivos à Companhia”⁴³, seria “claramente descabida a acusação de violação ao art. 153 da Lei das S.A.”⁴⁴, tendo em vista que os acusados “atuaram em perfeita consonância com todas as orientações que lhe estavam disponíveis à época”⁴⁵.

73. Neste sentido, segundo a defesa, condenar os acusados no caso em tela seria uma “aplicação retroativa de nova interpretação”, o que é vedado pelo art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei n.º 9.784/2000.

Inexistência de Prejuízo para a Companhia

74. Por fim, os acusados argumentaram que o montante calculado pela Acusação, como suposto prejuízo da Companhia, poderia corresponder ao efetivo ganho dos executivos com a operação. No entanto, “qualquer ganho dos Executivos com as ações adquiridas no âmbito do Plano BM&F somente comprovam que o plano cumpriu seu objetivo de incentivar os administradores a atuar de maneira a gerar valor aos acionistas – valor esse que se reflete no incremento de preço das ações no mercado”⁴⁶.

75. Assim, os acusados alegam que, ao contrário do que teria sido afirmado pela Acusação, não teria havido dano ou prejuízo para a Companhia, já que a outorga e exercício das opções, sob a ótica contábil, acabaria por ter um efeito neutro na posição patrimonial da Companhia.

Razões de defesa de Edemir Pinto

⁴² De acordo com os acusados, “[s]omente a partir da edição ICVM 480/09 e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (...) que a CVM passou a exigir que mais informações sobre planos de remuneração baseado em ações fossem disponibilizadas aos acionistas. Com o advento do Formulário de Referência (especialmente os itens 13.4 a 13.8), passou-se a requerer o disclosure de diversas informações do plano em si” (doc. SEI 1245042, pág. 2226).

⁴³ Doc. SEI 1245042, pág. 2226.

⁴⁴ Doc. SEI 1245042, pág. 2226.

⁴⁵ Doc. SEI 1245042, pág. 2226.

⁴⁶ Doc. SEI 1245042, pág. 2229.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Prescrição

76. Preliminarmente, a defesa alega que as condutas supostamente ilícitas imputadas ao acusado teriam sido praticadas entre 2008 e 2009. Assim, fazendo menção ao art. 1º da Lei nº 9.873/1999, sustenta que a ação punitiva da CVM, em relação a Edemir Pinto, estaria prescrita.

77. Neste sentido, a defesa argumentou que o “*defendente somente tomou ciência da investigação contra ele instaurada quando a CVM lhe encaminhou o Ofício CVM/SPS/GPS-3 nº 027/2016, datado de 08.04.2016, data posterior, portanto, ao decurso do último prazo prescricional relativo às supostas irregulares que lhe são imputadas*”⁴⁷, de modo que teria transcorrido mais de cinco anos entre os atos supostamente irregulares e a data em que o acusado teria recebido a primeira notificação acerca da investigação e curso.

78. Além disso, de acordo com o acusado, sua citação para apresentação desta defesa teria ocorrido apenas em janeiro de 2018, sendo que as hipóteses estabelecidas nos incisos III e IV do art. 2º da Lei nº 9.873/1999 seriam “*claramente inaplicáveis ao presente Processo*”⁴⁸, assim como não teria ocorrido “*qualquer ato inequívoco que tenha importado apuração dos fatos objeto do presente Processo em relação ao Defendente, capaz de interromper o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da ação punitiva da CVM*”⁴⁹. Por fim, mencionou, ainda, que tampouco seria aplicável ao caso em questão o disposto no § 2º do art. 1º da mencionada Lei, na medida em que a conduta alegadamente irregular não constituiria ilícito de natureza penal.

Mérito

Relevância do contexto das supostas irregularidades

79. De acordo com Edemir Pinto, seria “*de vital relevância para o correto entendimento dos fatos objeto do presente Processo que eles sejam analisados dentro do contexto que ocorreram, assim como em razão das práticas de mercado e das exigências regulamentares vigentes à época*”⁵⁰.

⁴⁷ Doc. SEI 1245042, pág. 2249.

⁴⁸ Doc. SEI 1245042, pág. 2246.

⁴⁹ Doc. SEI 1245042, pág. 2249.

⁵⁰ Doc. SEI 1245042, pág. 2251.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

80. Neste sentido, argumentou que as informações fornecidas aos acionistas sobre o Plano BM&F e a recepção de suas regras pela BM&FBovespa por ocasião da assembleia geral realizada em 08.05.2008 observaram estritamente o que seria exigido pela regulamentação vigente à época, de modo que não se poderia buscar avaliar a mencionada prestação informacional a partir dos padrões impostos após as Instruções CVM nº 480⁵¹ e 481⁵², ambas de 2009.

Regularidade da manutenção dos direitos relativos ao Plano BM&F

81. A defesa alegou que todos os 4 ex-diretores (os Srs. A. C. F., M. A. T., O. Y. e R. M. M.) mantinham, anteriormente às suas respectivas nomeações como diretores, vínculos empregatícios com a Companhia, os quais teriam passado a estar suspensos, nos termos da Súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho⁵³. Assim, sustentou que tal suspensão do contrato de trabalho não teria implicado a perda, por parte dos ex-diretores, da condição de empregados da Companhia, tendo em vista que o contrato de trabalho não teria sido extinto em decorrência da eleição para o cargo estatutário, mas, sim, apenas suspenso.

82. Neste sentido, o acusado argumentou que *“as renúncias por eles apresentadas não constituíram ato jurídico apto a operar o seu desligamento da BM&FBOVESPA – pois o vínculo empregatício com a Companhia continuava mantido –, importando apenas no restabelecimento do contrato de trabalho, conforme esclarecido pelo Professor Estevão Mallet, em Parecer Jurídico que analisou a questão sob a ótica do Direito do Trabalho”*⁵⁴. Desta forma, asseverou que tal desligamento apenas teria ocorrido no momento em que os ex-diretores tiveram seus contratos de trabalho efetivamente rescindidos, ato que teria sido realizado por iniciativa da própria BM&FBovespa.

83. Ainda segundo o acusado, *“a situação em tela não se enquadra na hipótese constante do item 8.2 (a) do Plano BM&F – desligamento da Companhia por vontade própria – como busca fazer parecer a SPS, mas sim na hipótese prevista no item 8.2 (c) – desligamento da Companhia por vontade desta – uma vez que a cessação do vínculo*

⁵¹ Editada em 07.12.2009.

⁵² Editada em 17.12.2009.

⁵³ Súmula nº 269 do TST: *“DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego”*.

(https://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-269)

⁵⁴ Doc. SEI 1245042, pág. 2258.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de tais beneficiários com a BM&FBOVESPA (seu efetivo desligamento) decorreu da demissão sem justa causa por parte da Companhia, não da simples renúncia ao cargo estatutário”⁵⁵.

84. Ademais, a defesa alegou que seria impróprio presumir que tal tema não teria sido levado a conhecimento do conselho de administração da Companhia, sendo, ainda, que seria totalmente equivocado o exercício feito pela Acusação no sentido de que teria havido um dano à BM&FBovespa de cerca de R\$ 19,9 milhões, haja vista que:

- (a) o valor que os ex-diretores poderiam auferir da negociação das ações decorrente do exercício de suas opções não corresponde à existência de mesmo valor para a Companhia, já que não houve pagamento efetuado pela BM&FBovespa;
- (b) caso a BM&FBovespa emitisse no mercado um número de ações equivalente ao que resultou do exercício das opções, o preço não seria equivalente ao valor de cotação das ações de sua emissão na data em que foram negociadas;
- (c) a outorga e o exercício das ações não teriam acarretado aumento ou redução patrimonial da Companhia; e
- (d) a comparação feita pela Acusação entre o valor do suposto prejuízo e o montante da remuneração global da administração seria descabível⁵⁶, pois a assembleia geral teria aprovado a proposta de remuneração global, bem como a recepção de todas as opções concedidas com base no Plano BM&F.

Regularidade da celebração dos aditamentos aos contratos de opção de compra de ações

85. De acordo com o acusado, a celebração dos aditamentos teria tido como razão fundamental o interesse na retenção dos profissionais-chaves para a BM&FBovespa, de

⁵⁵ Doc. SEI 1245042, pág. 2259.

⁵⁶ Para melhor referência, a Acusação fez a seguinte comparação: “A título de comparação da magnitude dessa despesa, em ata da AGE da Nova Bolsa S.A., realizada em 08.05.2008, além dos temas referentes à incorporação, foi deliberado: “5.17. Fixar em até R\$ 3.600.000,00 a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e em até R\$ 8.200.000,00 a remuneração global anual da Diretoria da Companhia, estando incluídos, nestes valores, nos termos do Art. 152 da Lei nº 6.404/76, todos os benefícios e verbas de representação”. Esse custo de R\$ 8.200.000 foi para a diretoria eleita nessa mesma data, 08.05.2008, composta então por 8 membros, em 20.05.2008 passou a ser composta por 7 membros e em 01.07.2008 voltou a ser composta por 8 membros. Por sua vez, o custo indevido de R\$ 19.901.020,00 foi incorrido com a dispensa de apenas quatro diretores. Ou seja, gastou-se indevidamente com quatro diretores mais que o dobro da remuneração anual global da Diretoria da Companhia, composta em média por oito diretores” (doc SEI 1245011, pág. 2080).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

forma que os beneficiários teriam sido *“identificados como pessoas cujo elevado know how técnico e conhecimento sobre as atividades da BM&F seriam fundamentais e indispensáveis no cenário que se avizinhava, com a iminente integração das atividades da BM&F e da BOVESPA”*⁵⁷.

86. Neste sentido, a outorga das opções com base nos aditamentos teria tido o objetivo de manter tais profissionais alinhados com o desempenho futuro da Companhia, de modo a os vincular à expansão, êxito e consecução de seus objetivos, razão pela qual teria se fixado que, mesmo no caso de demissão, o exercício das opções apenas poderia ser realizado após 02.01.2010, ou seja, cerca de vinte meses após a outorga. Assim, o acusado alegou que, mesmo que os profissionais em questão fossem desligados da BM&FBovespa, *“era de interesse desta que eles mantivessem seus interesses alinhados aos da Companhia, evitando, por exemplo, que fossem trabalhar em empresas concorrentes”*⁵⁸.

87. Ademais, a defesa sustentou que a celebração dos Aditamentos não teria acarretado qualquer prejuízo à Companhia. *“Pelo contrário, a outorga das Opções Adicionais, da forma em que foi realizada, se mostrou menos gravosa para a BM&F – e, conseqüentemente, para a BM&FBOVESPA – do que se tivesse sido efetivada nos estritos moldes do Plano BM&F”*⁵⁹, sendo que tal plano autorizava *“certo grau de customização dos contratos de opção, em consideração às particularidades de cada situação concreta”*⁶⁰ e as condições estabelecidas nos aditamentos não representariam nenhum tipo de ônus adicional pela Companhia.

88. Ainda de acordo com o acusado, todos os atos relacionados ao Plano BM&F teriam sido expressamente ratificados pelos acionistas da Companhia, incluindo a celebração dos aditamentos, sendo certo que seus acionistas, segundo as normas e práticas de mercado vigorantes à época, estavam informados de todas as condições dos contratos celebrados.

Inexistência de justificativa para aplicação de penalidades

89. O acusado sustentou que sua atuação durante os fatos teria se pautado na defesa e proteção dos interesses da Companhia, sendo que, caso se recusasse a reconhecer o direito

⁵⁷ Doc. SEI 1245042, pág. 2278.

⁵⁸ Doc. SEI 1245042, pág. 2278.

⁵⁹ Doc. SEI 1245042, pág. 2279.

⁶⁰ Doc. SEI 1245042, pág. 2281.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de os quatro ex-diretores exercerem suas opções, importaria em um possível litígio na esfera trabalhista, além de trazer danos reputacionais para a Companhia.

90. Por fim, o acusado alegou que os interesses da Companhia foram observados na celebração dos Aditamentos, tendo em vista que tal celebração tinha como objetivo “manter os interesses de profissionais altamente qualificados e com extenso conhecimento sobre as atividades da BM&F alinhados aos da BM&FBOVESPA no longo prazo, ainda que eles viessem a deixar os seus quadros, evitando que eventualmente passassem a trabalhar para empresas concorrentes”⁶¹.

Razões de defesa conjunta de Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Félix Cintra Neto, René Marc Kern e Roberto Rodrigues

Preliminares

Inépcia da Acusação

91. Preliminarmente, a defesa sustentou que a peça acusatória seria inepta, na medida em que não haveria nexo causal entre diversos dos fatos narrados e muitas das alegações constantes do relatório de acusação. Neste sentido, argumentou que não existiria “a menor correspondência lógica entre o relato da peça acusatória e suas conclusões, inclusive quanto à autoria e materialidade das acusações formuladas contra os Defendentes”⁶².

92. Os acusados alegam, ainda, a ausência de individualização das condutas que seriam apontadas como ilícitas, de modo que deveria ser declarada a nulidade do presente PAS.

Prescrição

93. Ainda preliminarmente, os acusados alegaram que os fatos discutidos neste processo teriam ocorrido entre 20.09.2007 e 02.02.2009, o que dificultaria a produção de provas e a formulação de suas defesas.

94. A defesa, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, suscitou a ocorrência da prescrição. Desta forma, argumentou que “o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos no que concerne aos Defendentes – em que estavam, portanto, presentes os elementos de bilateralidade e de identificação da existência de um procedimento de

⁶¹ Doc. SEI 1245042, pág. 2292.

⁶² Doc. SEI 1245043, pág. 2402.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

natureza investigatória – foi representado pelos Ofícios/CVM/SPS/GPS-3/Nº 11, 13, 19 e 20/2016, recebidos pelos ora Acusados em abril de 2016, assim, após decorridos 7 (sete) anos do último evento apontado”⁶³, ou seja, prazo maior que o tempo prescricional de cinco anos estabelecido pela Lei.

95. Os acusados alegam, ainda, que, *“na hipótese de o Colegiado vir a interpretar de forma diversa a contagem do prazo prescricional, dispensando a necessidade da bilateralidade do ato em relação ao conceito de ‘ato inequívoco de apuração dos fatos’ (...), a referida contagem de prazo deveria, então, ser efetuada a partir da data da prática do ato inicial que dá ensejo à apuração da CVM”,* que seria a Reunião do Colegiado da CVM de 29.05.2012. No entanto, *“desde 29.05.2012, data em que se decidiu pela apuração das eventuais irregularidades, até a intimação para apresentação de defesa, já decorreram mais de cinco anos, o que faz com que esteja prescrita a ação punitiva da CVM”*⁶⁴.

Mérito

Inocorrência de violação do dever de diligência

96. A defesa alegou que o conselho de administração sempre supervisionou o cumprimento dos princípios básicos do Plano BM&F. Neste sentido, no entanto, asseveraram que *“como os fatos discutidos no caso remetem ao período de 2007 a 2009, os procedimentos atinentes a controles internos e respectivos processos de documentação e registros de atos de governança corporativa estavam ainda no início de sua implantação no mercado brasileiro”*⁶⁵, de modo que não se poderia comparar, portanto, com as práticas atuais.

97. Além disso, de acordo com os acusados, os planos de opções, respectivas outorgas e execução teriam sido devidamente evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia encerradas em 31.12.2008, de forma a abranger informações a respeito das outorgas concedidas a colaboradores da BOVESPA e da BM&F, que teriam sido, posteriormente, assumidas pela BM&FBovespa. Assim, dado que não teria havido *“quaisquer indicações, factuais ou documentais, sobre a existência de red flags na outorga ou na gestão de opções de compra de ações a colaboradores da B3, não se*

⁶³ Doc. SEI 1245043, pág. 2406.

⁶⁴ Doc. SEI 1245043, p. 2406-2408.

⁶⁵ Doc. SEI 1245043, p. 2417.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

poderia sustentar, no caso concreto, que os integrantes do Conselho de Administração da Companhia pudessem ser seriamente acusados de qualquer falha no exercício de seus deveres legais e estatutários, ainda mais porque não havia qualquer irregularidade a ser detectada”⁶⁶.

Regularidade dos atos praticados pelos acusados

98. Em relação à suposta irregularidade da antecipação de exercício de direitos por beneficiários do Plano BM&F, os acusados argumentam que, após a integração da BM&F e da Bovespa, houve dispensas de administradores e funcionários, como de forma já esperada. Portanto, a renúncia dos quatro ex-diretores apontados no caso teria um caráter formal e incomparável com um suposto pedido de demissão do emprego. Neste sentido, o desligamento de tais diretores não teria ocorrido por vontade dos beneficiários conforme cláusula 8.2(a) do Plano BM&F, “*uma vez que todos os diretores estavam vinculados à Companhia por contratos de trabalho sob regime celetista*”⁶⁷, mas, sim, por vontade da Companhia, mediante demissão sem justa causa, o que estaria de acordo com a Cláusula 8.2.(c) de tal plano.

99. Assim, os acusados alegam, com base no parecer do Professor Estêvão Mallet, que:

- (a) as eleições de empregados para funções diretivas em sociedade anônima implicariam uma suspensão do contrato de trabalho, sendo que a suspensão cessaria com a renúncia e, conseqüentemente, restabelecimento da eficácia da relação jurídica original;
- (b) mesmo após a renúncia, seria irrelevante o fato de os ex-diretores terem voltado ao exercício de suas funções ou não, pois o restabelecimento do contrato apenas dependeria da cessação da suspensão advinda da renúncia;
- (c) o dispositivo que seria aplicável para a situação em tela seria o item 8.2(c) do Plano BM&F;
- (d) é possível que um agente ocupe cargo estatutário de administrador sem ter vínculo empregatício com a Companhia, o que se enquadraria no item 8.2(a) do Plano BM&F, ao contrário do afirmado pela Acusação; e

⁶⁶ Doc. SEI 1245043, p. 2417.

⁶⁷ Doc. SEI 1245043, pág. 2421.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(e) caso a Companhia não admitisse o exercício de direitos pelos beneficiários, ter-se-ia base jurídica para um passivo trabalhista. Por esses motivos, não haveria nenhuma *red flag* que pudesse fazer com que o Conselho de Administração impugnasse ou suspendesse os exercícios dos direitos que decorrem do Plano BM&F.

100. Ademais, os acusados argumentam, também, que a remuneração auferida pelos beneficiários do Plano BM&F não teria gerado “custo indevido” para a Companhia, pois os beneficiários “*eram legítimos detentores de opções de aquisição de ações da Companhia, e no momento de seu legítimo exercício, a respectiva emissão ou entrega de ações aos beneficiários acarretaria ‘custo’, sem sombra de dúvida, ‘legítimo’*”⁶⁸.

101. Ainda de acordo com os acusados, seria descabida a assertiva da Acusação no sentido de comparar o “‘custo’ incorrido com a dispensa de quatro diretores com a remuneração anual global da diretoria (oito diretores)”⁶⁹, na medida em que não caberia à CVM “*imiscuir-se no âmbito das decisões empresariais tomadas com base em deliberações da assembleia geral dessa natureza, a menos que estivesse diante de um quadro de fraude, que não é o caso*”⁷⁰.

Aditamentos aos instrumentos de outorga de opções de compra de ações

102. A defesa menciona que não teria havido acusação expressa aos acusados quanto às supostas desconformidades com as regras do Plano BM&F no momento em que foram celebrados os Aditamentos, contudo, sustenta que tal ato estaria em conformidade com os princípios e diretrizes do Plano BM&F. Neste sentido, os acusados argumentaram que seria vital para a estratégia de integração da BM&F S.A., à época, um alinhamento de interesses com alguns executivos, assim como que se evitasse que os referidos executivos fossem trabalhar para empresas concorrentes.

103. Assim, sustentam que o Plano BM&F trazia flexibilidade, de modo a permitir a revisão de algumas de suas condições, no interesse da Companhia e de seus acionistas, sem, no entanto, alterar seus princípios básicos, conforme previsto na Cláusula 10.5. Desta forma, os acusados asseveram que teria resultado, “*deste conjunto de contratos, indiscutível benefício para a Companhia, ainda que, para os executivos beneficiários dos*

⁶⁸ Doc. SEI 1245043, pág. 2426.

⁶⁹ Doc. SEI 1245043, pág. 2427.

⁷⁰ Doc. SEI 1245043, pág. 2427.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Lotes Adicionais, tivesse sido mais gravosa a alteração formulada nos Aditamentos, ao prorrogar para 01 de janeiro de 2010 a data inicial de exercício das opções, sendo que a prestação de serviços poderia se encerrar em data anterior e, ainda assim, ficavam os beneficiários adstritos ao regime de ‘non compete’”⁷¹.

104. Ademais, a defesa esclareceu que “a outorga dos lotes adicionais não ultrapassou o limite de 3% do capital social, em acordo com as disposições do Plano BM&F, nem ultrapassou o prazo máximo previsto para o exercício das opções, ou o limite de diluição do capital de até 5% do capital em relação ao total de ações emitidas”⁷².

105. Por fim, a defesa alegou que, “[c]onsolidando a conformidade dos Aditamentos com o Plano”⁷³, os acionistas, por unanimidade, teriam aprovado, em assembleia geral extraordinária realizada em 08.05.2008, a sucessão, pela Companhia, de todos os contratos individuais celebrados entre a BM&F e os beneficiários do Plano BM&F.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PAS

106. Em 19.06.2018, o presente Processo foi originalmente sorteado para o Diretor Henrique Machado. Ao final de seu mandato, antes de minha posse, o Processo foi redistribuído. No dia 12.01.2021 o Diretor Gustavo Gonzalez foi designado seu relator. Com sua renúncia, houve nova redistribuição e no dia 09.03.2021 o Presidente Marcelo Barbosa foi designado seu relator. Finalmente, no dia 09.09.2021, fui designado Diretor Relator.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021.

Fernando Caio Galdi

Diretor Relator

⁷¹ Doc. SEI 1245043, pág. 2430.

⁷² Doc. SEI 1245043, pág. 2431.

⁷³ Doc. SEI 1245043, pág. 2431.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO DFG

(Doc. SEI nº 1366955)

Assina o Relatório DFG B3, nos termos do Doc. SEI nº 1366955.

FERNANDO CAIO GALDI

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 14/10/2021, às 18:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1366959** e o código CRC **3D093F06**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1366959** and the "Código CRC" **3D093F06**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.003480/2021-22

Reg. Col. nº 1056/18

Acusado: Edemir Pinto
Manoel Felix Cintra Neto
Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo
Gustavo Henrique de Barros Franco
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo
René Mark Kern
Roberto Rodrigues

Assunto: Responsabilidade de membros do conselho de administração e de membro da diretoria da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, antiga BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por descumprimento de deveres fiduciários no exercício de suas atribuições, em violação aos artigos 153 e 154 da Lei nº 6.404/1976.

Relator: Diretor Fernando Caio Galdi

Voto

I. Considerações Iniciais

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SPS, em conjunto com a PFE, para apurar supostas irregularidades relacionadas à execução do Plano BM&F, aprovado na assembleia geral da Companhia de 08.05.2008, que estabeleceu as principais condições a serem observadas na celebração de contratos de outorga de opções de compra de ações com funcionários da BM&FBovespa.
2. A acusação pode ser dividida em dois grandes grupos. O primeiro deles está relacionado ao suposto descumprimento, pelo Sr. Edemir Pinto, na qualidade de Diretor Geral da BM&F e posteriormente como Diretor Presidente da BM&FBovespa, do art. 154,

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que acompanha este voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caput, da Lei nº 6.404/1976. De acordo com a Acusação, o Sr. Edemir Pinto teria deixado de exercer suas atribuições no intuito de lograr os fins e interesses da Companhia, ao **(i)** não reconhecer, nos termos previstos no Plano BM&F, a extinção de opções de compra atribuídas a quatro ex-diretores da BM&FBovespa, que renunciaram aos seus cargos entre junho de 2008 e fevereiro de 2009; e **(ii)** celebrar aditamentos a contratos de outorga de opção de compra com seis funcionários da BM&FBovespa, em condições diversas daquelas previstas no Plano BM&F.

3. O segundo grupo de irregularidades é referente à suposta violação ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/1976, por parte de membros do conselho de administração da BM&FBovespa, por não terem fiscalizado a atuação do Diretor Presidente no que se refere às condutas acima descritas.

4. O restante do presente voto está dividido em cinco seções adicionais. A segunda seção trata das preliminares de mérito alegadas pelos acusados em suas defesas. A terceira aborda aspectos relacionados ao plano BM&F de outorga de opções de compra e suas principais finalidades. Já a quarta e a quinta seções enfrentam, respectivamente, as acusações de violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por parte do Diretor Presidente, e ao art. 153 da mesma lei, por parte de membros do conselho de administração da BM&FBovespa. E, por fim, a sexta seção, conclui a argumentação.

II. Preliminares

Prescrição

5. Inicialmente, em suas respectivas defesas, todos os acusados alegam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM, nos termos do art. 1º, *caput* da Lei nº 9.873/1999², tendo em vista que transcorreram mais de cinco anos entre os fatos objeto deste PAS e o momento em que foram notificados acerca da investigação, em 2016³.

² Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

³³ Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº11/16, de 08.04.2016, ao Sr. Roberto Rodrigues; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº12/16, de 08.04.2016, ao Sr. Roberto Rodrigues; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº19/16, de 08.04.2016, ao Sr. Manoel Feliz Cintra Neto; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº20/16, de 08.04.2016, ao Sr. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº11/16, de 08.04.2016; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº23/16, de 08.04.2016, ao Sr. Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº11/16, de 08.04.2016; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº25/16, de 08.04.2016, ao Sr. Gustavo Henrique de Barros Franco; Ofício CVM/SPS/GPS-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6. Nesse sentido, para tratar de tais alegações é necessário, em primeiro lugar, identificar o marco inicial da fluência do prazo prescricional para cada uma das acusações.

7. Com relação aos membros do conselho de administração acusados, a imputação feita é de violação do dever de diligência, artigo 153 da Lei das S.A., pela não fiscalização da execução do Plano BM&F no período que vai de 29.09.2007⁴ até 02.02.2009⁵. Trata-se, a meu ver, de infração de natureza *permanente*, de modo que a fluência do prazo prescricional se inicia com a cessação da infração. Ocorre que a Acusação não deixa claro em que momento isso teria ocorrido para cada um dos conselheiros. Sendo assim, entendo que deve ser considerada a data do último ato reputado como ilegal, que consiste na data de antecipação da carência das opções outorgadas para o R.M.M, indicada acima, visto que até tal data, segundo a Acusação, não foram adotadas medidas adequadas para a fiscalização do Plano BM&F e todos os acusados ainda exerciam seus mandatos – ou seja, a conduta omissiva reputada irregular ainda estava em curso.

8. No que diz respeito ao Sr. Edemir Pinto, Diretor Geral da BM&F e posteriormente Diretor Presidente da BM&FBovespa, a Acusação imputa diversas violações específicas ao Plano BM&F. Por essa razão, entendo que elas devem ser tratadas individualmente, como infrações autônomas, com início dos respectivos prazos prescricionais na data em que cada uma delas ocorreu. Assim, o primeiro ato supostamente ilegal teria ocorrido em 30.04.2008⁶ e último em 02.02.2009⁷.

9. Dito isto e estabelecidos os marcos iniciais, é necessário verificar se houve qualquer interrupção da prescrição até a formulação da acusação. A resposta no caso concreto, a meu ver, é positiva. Foram praticados pela CVM diversos atos inequívocos voltados à apuração dos fatos, capazes de interromper a prescrição, nos termos do art. 2º, inciso II da Lei nº 9.873/1999⁸.

10. Neste sentido, podem-se mencionar: **(i)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 1304/12 enviado à Companhia em **30.07.2012**, solicitando manifestação, dentre outros temas, sobre

3/Nº27/16, de 08.04.2016, ao Sr. Edemir Pinto; Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº13/16, de 08.09.2016, ao Sr. René Mark Kern.

⁴ Data da aprovação do Plano BM&F.

⁵ Data do último ato reputado como ilegal, que consiste na data da antecipação da carência das opções outorgadas a R.M.M.

⁶ Outorga dos aditamentos ao Plano BM&F.

⁷ Vide nota [5], acima.

⁸ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o Plano BM&F; **(ii)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 1512/12 enviado à Companhia em **24.10.2012**, solicitando manifestação sobre o Plano BM&F; **(iii)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 33/13 de **14.01.2013** solicitando a relação de beneficiários, data de exercício e a quantidade de opções outorgadas/exercidas; **(iv)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 132/13 de **04.02.2013** solicitando esclarecimentos adicionais sobre as opções; **(v)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 151/13 de **19.02.2013** sobre Comissão de Indicação e Remuneração e Inobservância do período de *vesting*; **(vi)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 175/13 de **28.02.2013** solicitando esclarecimentos sobre as contradições encontradas entre renúncias em atas de Reuniões de Conselho de Administração, demissões sem justa causa e readmissões; **(vii)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 196/13 de **15.03.2013** solicitando esclarecimentos, dentre outros, sobre a existência de outros diretores que celebraram contratos de prestação de serviços após deixarem seus cargos; **(viii)** o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 257/13 de **26.04.2013** solicitando informar os motivos pelos quais apenas um diretor não exerceu as opções de compra em razão da demissão; **(ix)** o Ofício /CVM/SEP/GEA-3/Nº 322/13 de **20.05.2013** sobre supostas inconsistências nos desligamentos de 2 diretores; **(x)** o Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº17/15 de **10.04.2015** pedindo documentos sobre os vínculos de funcionários; **(xi)** o Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº52/15 de **01.07.2015** solicitando documentos, dentre outros, sobre renúncias, desligamentos e readmissões; **(xii)** o Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº94/15 de **03.12.2015** pedindo documentos sobre os vínculos de funcionários; **(xiii)** o Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº08/16 de **18.03.2016** pedindo atas do Comitê de Indicação e Remuneração e documentos referentes ao plano de opções; e **(xiv)** os ofícios enviados aos acusados em **08.04.2016** solicitando esclarecimentos sobre os fatos. Por fim, em **14.12.2017** foi concluído o termo de acusação, com a expedição das intimações dos acusados para a apresentação de defesa em **28.12.2017**.

11. Portanto, é notória a ocorrência de eventos interruptivos que impediram a consumação da prescrição com relação aos fatos objeto do PAS, uma vez que foram praticados sucessivamente, antes que prazo quinquenal transcorresse incólume.

12. Neste ponto, é preciso afastar dois argumentos trazidos pelas defesas dos acusados.

13. Primeiro, não é necessária ciência do acusado para que determinado ato importe apuração do fato e, conseqüentemente, seja apto a interromper a prescrição. Basta que ele evidencie de forma inequívoca que a Autarquia estava agindo para colher informações sobre determinado acontecimento e, a partir delas, formar sua convicção sobre o assunto. Esse



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entendimento foi bem explicado no âmbito do PAS 22/94⁹, consolidado por diversos precedentes posteriores do Colegiado¹⁰.

14. É evidente que os ofícios mencionados acima, ao solicitarem esclarecimentos e documentos sobre o tema, tinham justamente o objetivo de investigar os fatos que resultaram na instauração deste PAS e, portanto, interromperam a prescrição antes da consumação do prazo quinquenal para todas as imputações objeto deste PAS.

15. Segundo, ao contrário do que alegam os acusados, também é consolidado o entendimento deste Colegiado¹¹ no sentido de que a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez, tal como ocorreu neste PAS, em virtude da ocorrência de diversos atos inequívocos voltados à apuração dos fatos.

16. Por essas razões, afasto a preliminar de prescrição arguida pelos acusados.

⁹ Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação de voto do Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos: Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2º, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2º, da Lei n.º 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2º, II, da Lei n.º 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’”.

¹⁰ PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j.02.04.2019; PAS CVM nº 06/2016, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 24.08.2020; PAS CVM nº RJ 2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. 30.01.2020; PAS CVM nº RJ2005/6924, j. 31.10.2006.

¹¹ PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez; j.02.04.2019; PAS CVM nº 01/2011, j. em 27.02.2018, Dir. Rel. Henrique Machado; PAS CVM nº 11/2013, j. em 30.01.2018, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez; PAS CVM nº 12/2013, j. em 24.05.2016, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba; PAS CVM nº RJ2014/5807, j. em 15.03.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM nº RJ2011/11073 e nº RJ2010/3695, ambos julgados em 15.12.2015, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº 14/2009, j. em 11.08.2015, Dir. Rel. Luciana Dias; PAS CVM nº 04/2009, j. em 11.06.2013, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Moraes; PAS CVM nº 03/2006, j. em 01.12.2010, Dir. Rel. Eli Loria; PAS CVM nº RJ2008/2570, j. em 12.05.2009, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

17. Especificamente, com relação à possível prescrição intercorrente suscitada pelas defesas¹², que passa a incidir a partir da instauração do processo administrativo sancionador e com a intimação dos acusados para apresentação de defesas, verifico que, no presente caso, houve atos aptos a interromper o prazo prescricional trienal.

18. Após a intimação dos Acusados em 28.12.2017¹³, a Secretaria Executiva, por meio de despacho datado de 19.06.2018¹⁴, distribuiu o processo para relatoria do ex-Diretor Henrique Machado, configurando ato expedido para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão e, portanto, apto a interromper a prescrição intercorrente.

19. Adicionalmente, relevante destacar que, em 23.03.2020, foi publicada a Medida Provisória nº 928, dispondo sobre as “*medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus*”, que suspendeu até 20.07.2020 o transcurso dos prazos prescicionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 9.873, de 1999¹⁵.

20. Dessa maneira, levando em consideração o marco inicial do prazo prescricional, bem como os despachos relacionados e a suspensão temporal imposta pela Medida Provisória nº 928, não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inépcia da acusação

21. Dando sequência às suas alegações, os acusados Luiz Gonzaga, Manoel Félix, René Kern, Roberto Rodrigues e Gustavo Franco argumentam que a acusação seria inepta, sem elementos suficientes de autoria e materialidade, por: **(i)** ser vaga e genérica; **(ii)** não ter havido apuração precisa “*da conduta e dos esforços dos conselheiros*” durante o inquérito; **(iii)** não reunir provas suficientes; **(iv)** não individualizar as condutas dos acusados; **(v)** não identificar nexos entre os fatos narrados e a imputação feita aos acusados; e **(vi)** não indicar critérios claros para justificar a escolha do grupo de conselheiros acusado.

22. Entendo, contudo, que tais alegações não prosperam.

¹² Doc. SEI 1363686, Doc. SEI 1365398 e memorial entregue pela defesa dos Srs. Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Manoel Félix Cintra Neto, René Marc Kern e Roberto Rodrigues, via e-mail, em 01.10.2021.

¹³ Doc. SEI 1245011 p. 2103-2109

¹⁴ Doc. SEI 1245087

¹⁵ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Congresso/adc-93-mpv928.htm



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

23. A Acusação colocou de forma clara a imputação feita aos acusados, qual seja, não terem empregado, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, o cuidado e a diligência necessários para administrar o Plano BM&F, em violação ao artigo 153 da Lei das S.A. A Acusação descreveu, também, no Item III.1.5 as razões que levaram à sua conclusão com relação à responsabilização de tais indivíduos nos termos descritos acima, dando base suficiente para o exercício do direito de defesa.

24. Quanto ao critério para a definição do rol de acusados, o termo de acusação foi claro ao fazer constar expressamente¹⁶ que foram incluídos todos que ocuparam cargos no conselho de administração da Companhia desde o momento de aprovação do Plano BM&F incluindo também o período no qual ocorreram as irregularidades que, no entendimento da acusação, corroborariam a inexistência de controles adequados para a fiscalização do seu cumprimento pelo órgão. Não verifico, portanto, qualquer “seletividade” por parte da SPS.

25. Na mesma linha, entendo que não há vícios com relação à individualização das condutas posto que a acusação entendeu que o conselho de administração, como órgão colegiado, infringiu seu dever de monitoramento, de modo que os seus integrantes foram acusados por suas condutas supostamente omissivas¹⁷. Tivesse algum dos ex-conselheiros acusados apresentado, individualmente, algum questionamento no âmbito da companhia a respeito do assunto, isso certamente teria sido levado em consideração. Entretanto, não foi o caso, o que torna a acusação necessariamente dirigida a todos os conselheiros da época, indistintamente.

26. Ademais, ao contrário do que alegam as defesas, entendo que a SPS promoveu diligências específicas, ao longo da apuração, para formar sua convicção acerca das imputações feitas aos acusados. Por exemplo, constam dos autos ofícios enviados a todos eles¹⁸ questionando, dentre outros temas, sobre: **(i)** os mecanismos de controle estabelecidos

¹⁶ Doc. SEI 1245011, p. 2068-2094, item 90. “Consoante a tabela 2, observa-se que os membros 1 a 6 do CA estavam presentes na aprovação do Plano BM&F (evento 1), de modo que deveriam conhecer suas regras, já que foram definidos como seus administradores. Estes mesmos membros também estavam presentes na RCA de ratificação da delegação ao Diretor Geral, em 23.10.2007 (evento 2), portanto sabiam da delegação e, por óbvio, de seus deveres de fiscalização inerentes ao exercício de suas funções. Estavam presentes nos eventos 4 e 5, ou seja, foram informados das renúncias de Ailton Coentro Filho e Marco Aurélio Teixeira e do posterior pagamento de ações no exercício de opções destes que, conforme o Plano BM&F, deveriam ter sido extintas. Por fim, também estiveram presentes nos eventos 6 a 9, de modo que foram informados, enquanto membros do CA, sobre as renúncias de O.Y. e R.M., sendo certo que permaneceram no cargo nas datas de seus respectivos pagamentos a título de antecipação das opções ainda não exercidas.”

¹⁷ Nesse sentido, confira-se o voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/7961, de 30.01.2020.

¹⁸ Como exemplo: Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 018/2016 (Doc. SEI 1244999, p.266).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pelo conselho de administração para a execução do Plano BM&F e **(ii)** os responsáveis por verificar os contratos e cuidar do processo de pagamento de benefícios, questões que estão totalmente relacionadas às imputações que lhes foram dirigidas.

27. As outras questões suscitadas nas defesas, relativas à suficiência das provas colhidas e ao nexos causal entre os fatos narrados pela Acusação, bem como a imputação feita aos acusados, a meu ver, são questões que dizem respeito ao mérito do caso, não à viabilidade da Acusação. Portanto, elas serão tratadas na sequência deste voto.

28. Por essas razões, afasto a preliminar de inépcia da acusação arguida pelos acusados.

III. O plano de opção de compra de ações BM&F

29. Esta seção tem como objetivo apresentar o contexto de elaboração, aprovação e incorporação do Plano BM&F, de maneira a facilitar o entendimento de sua execução no caso concreto. Para tanto, nos próximos parágrafos são apresentados, em função de sua ordem cronológica, alguns fatos e comentários que considero importantes para a avaliação do caso.

30. A AGE instituidora do Plano de Opção de Compra de Ações da BM&F (“Plano BM&F”), ocorrida em 20.09.07, aprovou por unanimidade o plano de reconhecimento e incentivo (*stock options*) para os diretores e demais funcionários¹⁹.

31. O Plano BM&F estabeleceu como fundamento o alinhamento dos interesses dos acionistas da Companhia, aos de administradores, empregados e prestadores de serviços, da Companhia ou de outras sociedades sob seu controle, dando a oportunidade para que seus beneficiários se tornassem acionistas, a partir da outorga de opções de compra de ações da BM&F. Dessa forma, de acordo com a relação dos beneficiários do Plano BM&F emitida pela própria BM&F Bovespa, os contratos de outorga de opções de compra de ações decorrentes do Plano BM&F foram inicialmente concedidos a mais de 700 funcionários²⁰.

32. Três são os objetivos citados no documento que estabeleceu o Plano²¹: **(i)** estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia, **(ii)** alinhar o interesse dos acionistas da Companhia aos de administradores, empregados, e prestadores

¹⁹ Doc. SEI 1244938, p.377

²⁰ Doc. SEI 1244947, p. 876-887

²¹ Doc. SEI 1244940, p.531



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de serviços da Companhia ou outras sociedades sob seu controle e (iii) possibilitar à Companhia ou outras sociedades sob seu controle atrair e manter e ela vinculados administradores e empregados.

33. Levando-se em conta que o Plano BM&F foi estabelecido antes da realização da oferta pública de ações da Companhia, sua evidenciação no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias²², datado de 28 de novembro de 2007, demonstra que foi dado o *disclosure* das características do plano aos potenciais acionistas, conforme reproduzido integralmente a seguir:

“(...) Nosso plano de opção de compra ou subscrição de ações de nossa emissão foi aprovado por nossa Assembléia Geral em 20 de setembro de 2007. Trata-se de plano de reconhecimento e incentivo (stock option) para os atuais diretores e demais funcionários, para o qual serão destinados até 3% do nosso capital, respeitado o seguinte critério de vesting: 25% quando da concessão, zero no primeiro e no segundo anos, 25% no início do terceiro ano, 25% no início do quarto e 25% no início do quinto ano, com prazo máximo de exercício das opções até o final do sexto ano, podendo também ser concedido, pela Comissão de Indicação e Remuneração, mais 0,5% do capital social ao ano para novas contratações e para complemento do programa de retenção dos atuais executivos. A diluição do capital decorrente da totalidade dos planos em vigor (opções outorgadas e não exercidas) será limitada a 5%. Conforme deliberação do nosso Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de outubro de 2007, foi aprovada a concessão de tais opções, com a emissão de até 27.056.319 ações, observados os prazos de vesting já mencionados. Quando do exercício da totalidade das opções correspondentes ao plano aprovado, as ações adquiridas por nossos administradores serão equivalentes a, no máximo, 3% do nosso capital social atual e representarão uma redução da participação percentual dos nossos atuais acionistas também da ordem de 3%. O preço de exercício das opções com base na deliberação do Conselho de Administração que aprovou o plano acima descrito será de R\$1,00 por ação.” (grifou-se)

²² Doc. SEI 1244938, p.400



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Neste sentido, pode-se considerar, que o caráter retributivo do Plano BM&F, conforme argumentado pelas defesas²³ e divulgado pela Companhia²⁴, deva ser avaliado dentro do contexto de desmutualização e da oferta de ações da Companhia, e, posteriormente, dentro do processo de criação da BM&FBovespa.

35. Assim, em relação ao caso concreto, que é representado por uma reestruturação societária que envolveu um processo de desmutualização com posterior oferta pública de ações e combinação de negócios, pode-se fazer um paralelo com a literatura recente que reporta como comum o uso de mecanismos de pagamento adicionais²⁵, como planos de opções de compra de ações com condições diferenciadas, aos executivos da sociedade adquirida em situações de fusões e aquisições²⁶.

36. Adicionalmente, o Professor Brian Broughman considera que, em situações de combinações de negócios, os mecanismos de pagamento adicionais podem beneficiar os acionistas de maneira a reduzir a resistência dos executivos envolvidos, que temem perder seus empregos, de maneira a viabilizar a transação²⁷. Contudo, também há a visão de que mecanismos de pagamento adicionais podem ser utilizados para enriquecer os executivos às custas dos acionistas (“rent extraction”).

²³ Doc. SEI 1245042 e doc. SEI 1245043.

²⁴ Doc. SEI 1244940 p. 543 e 546.

²⁵ *Side payments are structured in a variety of different ways, including (i) merger bonuses (often structured as non-compete agreements); (ii) augmented parachute entitlements; (iii) employment or post-merger consulting contracts; (iv) ‘unscheduled’ stock options during merger; negotiations; or (v) a board seat with the acquiring firm. The dollar amounts paid out in such side deals are substantial. CEOs of publicly held target firms typically receive a larger aggregate payout from merger side deals (\$2 million) than from pre-merger golden parachute arrangements (\$1.5 million). (“CEO Side Payments in Mergers and Acquisitions”, BUY Law Review, Brian Broughman, 2017, p. 69).*

²⁶ *In acquisitions of both privately- and publicly-held firms, it is common for acquirers to offer the CEO (and sometimes other top executives) of the target firm either post-merger employment or some form of side payment.*

Side payments are not limited to the target CEO. Other members of the target firm’s senior management team sometimes receive side payments as well; however, to facilitate meaningful comparisons empirical studies typically focus on the CEO. See id. To the extent that other members of senior management are involved in merger negotiations the analysis in this Article applies to such individuals as well as to the CEO. For ease of terminology and to track existing data, however, I will typically refer to the target CEO rather than to the loose collection of target managers involved in merger negotiations who happen to receive side payments. (“CEO Side Payments in Mergers and Acquisitions”, BUY Law Review, Brian Broughman, 2017, p. 69).

²⁷ *On the one hand, side payments may benefit shareholders by countering managerial resistance to an efficient sale. Because an acquisition is likely to cause the target CEO to lose her job, future income, and various private benefits, she may credibly threaten to block the sale unless she is offered post-merger employment with the acquiring firm or a lucrative side payment to compensate for her loss. (“CEO Side Payments in Mergers and Acquisitions”, BUY Law Review, Brian Broughman, 2017, p. 70).*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Neste sentido, importante mencionar que a Assembleia Geral Extraordinária da Nova Bolsa S.A. (BMF&Bovespa), ocorrida no dia 08.05.2008, com participação dos acionistas representando a totalidade do capital da sociedade, recepcionou integralmente o Plano BM&F²⁸, com as suas características originais²⁹.

38. Em termos de evidenciação ao mercado, a Companhia relatou em suas demonstrações financeiras auditadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e aprovadas pela assembleia geral ordinária realizada em 28.04.2009³⁰: *“Em AGE de 20 de setembro de 2007 da BM&F S.A. foi aprovado o plano de opções de compra de ações de sua emissão (Plano), com o propósito de conferir direitos de aquisição sobre um número de ações, a título de reconhecimento e retenção dos funcionários da BM&F S.A. e, posteriormente, da Companhia, após 8 de maio de 2008, até o limite de 3% (três por cento) das ações do capital da Companhia. As outorgas de opções de ações realizadas no âmbito do plano de opção de compra de ações da extinta BM&F, foram assumidas pela BM&FBOVESPA, conforme deliberado na AGE de 8 de maio de 2008.”* (grifou-se).

39. No mesmo documento ainda se comenta³¹: *“O Plano foi concebido com o objetivo preponderante de conferir aos administradores e empregados da antiga BM&F (i) a retribuição por serviços prestados por seus beneficiários ao longo do período anterior ao processo de desmutualização e, também, (ii) a retenção dos profissionais ao longo dos quatro anos após a aprovação do Plano e ao IPO. Os principais aspectos inerentes às características de reconhecimento e aos critérios de alocação das opções concedidas foram: (i) preço de exercício fixo em R\$1,00, (ii) direito ao exercício das opções mesmo na hipótese de desligamento do beneficiário por iniciativa da Companhia, assim como no caso de aposentadoria, desligamento por invalidez ou falecimento do beneficiário, (iii) número de*

²⁸ Doc. SEI 1244999 (p. 88).

²⁹ “Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar:(...) (6) (i) a sucessão, pela Companhia, dos contratos de opção celebrados entre a BM&F e os beneficiários do Plano BM&F, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da BM&F de 20.09.2007, cujos termos e condições são ora ratificados, nos mesmos termos e condições contratados com cada um dos beneficiários que celebraram com a BM&F Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, cujas cópias encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, aprovando-se, em consequência, a substituição de todas as opções de compra de ações objeto de tais contratos com os beneficiários da BM&F, representando a possível emissão de até 19.226.391 (dezenove milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e uma) ações ordinárias da Companhia, por opções de compra da Nova Bolsa, nos mesmos termos e condições do Plano BM&F, bem como (ii) o novo Plano de Opção de Ações da Companhia (“Plano”), nos termos do Anexo VI;...”

³⁰ Doc. SEI 1244940 p. 546.

³¹ Doc. SEI 1244940 p. 547.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

anos trabalhados por cada beneficiário e (iv) prazo para cada um dos exercícios de opções.”

IV. Violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976

40. Dando início à análise de mérito, começo pelo primeiro grupo de acusações formuladas neste PAS: o suposto descumprimento pelo Sr. Edemir Pinto, na qualidade de Diretor Presidente da BM&FBovespa e anteriormente Diretor Geral da BM&F, do art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

41. No entendimento da Acusação, a violação a esse dispositivo teria se verificado em razão de duas condutas praticadas pelo então Diretor Presidente.

42. Primeiro, por não ter reconhecido a extinção dos direitos de aquisição de ações ainda não exercíveis (“Direitos de Aquisição de Ações”)³² na data do desligamento de quatro ex-diretores da BM&FBovespa, que renunciaram aos seus cargos entre junho de 2008 e fevereiro de 2009. Todos os ex-diretores mantinham vínculos celetistas com a Companhia previamente à assunção dos seus cargos estatutários, os quais foram encerrados por iniciativa da Companhia, sem justa causa, poucos dias após o pedido de renúncia apresentado pelo ex-diretores, conforme documentado nos autos³³.

43. Ante a renúncia dos ex-diretores, a Acusação entendeu que se aplicaria ao caso o item 8.2., (a), (i), do Plano BM&F, que determina que “*se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o **Beneficiário: (a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, rescindindo o contrato de prestação de serviço, ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, salvo decisão em contrário do Conselho de administração;***” (grifou-se). Por ter autorizado o exercício dos Direitos de Aquisição de Ações, em alegada contrariedade ao

³² O Plano BM&F previa que as opções outorgadas aos beneficiários deveriam ser exercidas em quatro lotes, sendo o primeiro deles com vencimento na data da concessão, o segundo no início do terceiro ano, o terceiro no início do quarto ano e o quarto no início do quinto ano. O prazo máximo estabelecido pelo plano para o exercício das opções outorgadas é até o final do sexto ano. Nesse sentido, são Direitos de Aquisição de Ações as opções cujo prazo de exercício ainda não tenha decorrido, em uma determinada data.

³³ Doc. SEI 1244943, p. 771-789.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

previsto no item 8.2., (a), (i), do Plano BM&F, a Acusação concluiu que o Sr. Edemir Pinto deixou de exercer suas atribuições no intuito de lograr os fins e interesses da Companhia.

44. A segunda conduta supostamente contrária ao interesse social praticada pelo Diretor Presidente se refere à celebração de aditamentos aos instrumentos particulares de outorga de opção de compra com seis funcionários da BM&FBovespa. Tais aditamentos estabeleceram que, em caso de desligamento do funcionário da BM&FBovespa por vontade da Companhia e sem justa causa, o prazo para o exercício dos Direitos de Aquisição de Ações seria de 180 dias a partir de 02.01.2010. No entendimento da Acusação, essa disposição seria contrária ao item 8.2., (c), do Plano BM&F, que determina que esses direitos passariam a ser automaticamente exercíveis, na data do desligamento.

45. Diante do exposto, passo a analisar, nos subtópicos abaixo, cada uma dessas condutas.

A não extinção dos Direitos de Aquisição de Ações

46. O art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 impõe aos administradores que exerçam as suas atribuições buscando sempre atingir os fins e interesses da companhia³⁴. Em outras palavras, o atendimento ao interesse social é o que deve guiar todos os atos praticados pelos administradores, que devem privilegiar o interesse da sociedade em relação a quaisquer outros interesses³⁵.

47. Aplicando essas noções ao caso concreto, me parece transparente que, para o atendimento ao interesse social e o consequente cumprimento do art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, os contratos de outorga de opção de compra de ações firmados com os diretores da então BM&F (posteriormente BM&FBovespa) deveriam ter sido executados de acordo com as disposições do Plano BM&F, aprovado por unanimidade na assembleia geral da BM&F de 20.09.2007 e ratificado nos mesmos termos e condições, na assembleia geral da

³⁴ “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.”

³⁵ Sobre a conduta esperada dos administradores em atendimento ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, Luiz Antonio de Sampaio Campos esclarece que “o interesse social e o cumprimento do objeto social limitam a liberdade e a discricionariedade do administrador, à medida que todos os atos, decisões e escolhas do administrador devem estar voltados primordialmente para o atendimento do objeto e do interesse social, embora deva ainda observar a função social da empresa e as exigências do bem público” (“Deveres e Responsabilidades” in LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 809).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Companhia de 08.05.2008, também por unanimidade³⁶. Afinal, a execução de tais contratos em condições diferentes daquelas previstas no Plano BM&F consistiria em uma violação à vontade dos acionistas da Companhia, manifestada em assembleia geral.

48. Isto posto, quanto à primeira conduta supostamente irregular praticada pelo Diretor Presidente – de não reconhecer, nos termos previstos no Plano BM&F, a extinção de opções de compra atribuídas a quatro ex-diretores da BM&FBovespa –, a defesa rebate a tese acusatória, argumentando que a renúncia apresentada pelos ex-diretores seria uma mera formalidade e que a iniciativa de seu desligamento teria sido da Companhia. Portanto, a situação se enquadraria, na realidade, no item 8.2., (c), (i) (e não “a”), do Plano BM&F, que dispõe que se o beneficiário **“for desligado da Companhia por vontade desta mediante demissão ou rescisão do contrato de prestação de serviços sem justa causa ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o Contrato de Opção, na data de sua desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência;”** (grifou-se).

49. Em outras palavras, a discordância da defesa em relação à Acusação refere-se ao fato de que, em sua visão, a execução pelo Sr. Edemir Pinto dos contratos de opção de compra celebrados com os ex-diretores teria se dado nos exatos termos previstos no Plano BM&F, não tendo violado o disposto no item 8.2., (a), (i), do plano, como alega a área técnica.

50. Portanto, para solucionar a presente controvérsia, deve-se determinar se houve ou não violação ao item 8.2., (a), (i), do plano, o que, por sua vez, depende da análise se o desligamento da Companhia ocorreu por vontade dos ex-diretores ou por vontade da BM&FBovespa. Isso porque, como se extrai da leitura do Plano BM&F, o item 8.2., (a), (i), apenas incidiria se o beneficiário **“desligar-se da Companhia por vontade própria [...]”** (grifou-se). Por outro lado, se o beneficiário **“for desligado da Companhia por vontade**

³⁶ Doc. SEI 1245042, pág. 344: “Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar: (...) (6) (i) a sucessão, pela Companhia, dos contratos de opção celebrados entre a BM&F e os beneficiários do Plano BM&F, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da BM&F de 20.09.2007, cujos termos e condições são ora ratificados, nos mesmos termos e condições contratados com cada um dos beneficiários que celebraram com a BM&F Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, cujas cópias encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, aprovando-se, em consequência, a substituição de todas as opções de compra de ações objeto de tais contratos com os beneficiários da BM&F, representando a possível emissão de até 19.226.391 (dezenove milhões, duzentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa e uma) ações ordinárias da Companhia, por opções de compra de ações da Nova Bolsa, nos mesmos termos e condições do Plano BM&F, bem como (ii) o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), nos termos do Anexo VI;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desta”, o item aplicável do Plano seria o 8.2., (c), (i), que determina que os Direitos de Aquisição de Ações seriam antecipadas, como de fato foram.

51. No caso concreto, a Acusação trouxe uma série de indícios que supostamente demonstrariam que a intenção de se desligar da Companhia seria dos ex-diretores.

52. Como se sabe, o Colegiado da CVM admite a condenação com base em prova indiciária, que, nas palavras da ex-diretora Norma Parente, “*é prova indireta, circunstancial, de inferências, partindo de dados e circunstâncias conhecidos (fatos provados) para os fatos desconhecidos (fatos probandos), através de um raciocínio de estrita lógica formal. Não é uma prova menor, nem imperfeita, e constitui prova suficiente a autorizar a condenação. É inquestionavelmente válida, porque fundada na razão, e tem um significativo peso na elucidação dos fatos*” (grifou-se)³⁷.

53. Não são, porém, quaisquer indícios que são capazes de ensejar uma condenação. É necessário que estejam presentes “*indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar*”³⁸ (grifou-se). Nessa linha, a existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvidas no julgador deve levar à absolvição dos acusados, conforme entendimento consagrado neste Colegiado³⁹.

54. Cabe, então, analisar os indícios e contraindícios presentes nos autos, a fim de verificar se é possível concluir, de maneira robusta e fundamentada, que a intenção de

³⁷ Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, j. em 18.08.2005.

³⁸ Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, j. em 18.08.2005. Nesse mesmo sentido, o Diretor Alexandre Rangel, em voto vista proferido no PAS CVM nº 05/14, j. em 15.06.2021, afirma que “*é preciso que o indício não deixe qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do fato principal (beyond a reasonable doubt – BARD). A pluralidade, robustez e convergência de indícios ajudam, como dito acima, a superar a dúvida razoável*”. E, ainda, PAS CVM nº 25/10, j. em 04.07.2017, Diretor Relator Henrique Machado: “*existência da prova indiciária representada por indícios múltiplos, veementes e convergentes, que permitam uma conclusão segura acerca do fato a ser provado*”.

³⁹ Cf., a título exemplificativo: (i) o voto da diretora relatora Norma Parente, no PAS CVM nº 06/95, j. em 05.05.2005: “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.”; e (ii) o voto do diretor relator Pablo Renteria no PAS CVM nº RJ2015/1760, j. em 11.09.2018: “119. No caso em apreço, se é verdade que a acusação logrou produzir alguns indícios significativos, que levantam suspeitas sobre a lisura da conduta de Luiz Aguiar, também é verdade que os argumentos e os contraindícios apresentados pela defesa possuem força o bastante para colocar em dúvida a suficiência das provas contidas nos autos. 120. Assim, considerado que há dúvida razoável sobre a configuração da conduta ilícita, entendo que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, Luiz Aguiar deve ser absolvido da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei das S.A.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desligamento de fato partiu dos ex-diretores. A Acusação reuniu os seguintes indícios para comprovar a sua tese:

- (i) os ex-diretores apresentaram renúncia aos seus cargos estatutários;
- (ii) alguns dias após a renúncia, os ex-diretores foram demitidos pela Companhia sem justa causa dos cargos celetistas que ocupavam, sendo que essa seria “a única hipótese prevista no Plano BM&F para que [os ex-diretores] fizessem jus à não extinção e ao exercício antecipado das opções sem a necessidade de análise pelo Conselho de Administração”;
- (iii) os ex-diretores “não desempenharam atribuições específicas, na qualidade de empregados sujeitos ao regime da CLT, após suas renúncias”; e
- (iv) “se a justificativa para a não extinção dos contratos de trabalho foi que tais renúncias não teriam o poder de gerar qualquer desligamento, já que haveria, para todos os diretores, vínculo celetista subjacente (parágrafo **Erro! Fonte de referência não encontrada.**), então a conclusão a que se chega é que não faria sentido algum o Plano BM&F citar, como causa de extinção de direitos ainda não exercíveis, a própria renúncia do beneficiário ao seu cargo de administrador no item 8.2, (a), (i)”.

55. Especificamente em relação a um dos ex-diretores, a Acusação menciona, ainda, que a sua intenção de se desligar da Companhia teria ficado evidente tendo em vista que, logo após a sua saída da BM&FBovespa, assumiu cargo em autarquia federal.

56. Quanto ao primeiro indício trazido pela Acusação – a renúncia dos ex-diretores aos seus cargos estatutários – a defesa contra-argumenta que, neste caso específico, não se pode interpretar a renúncia como uma manifestação de vontade dos ex-diretores de se desligarem da Companhia, nos termos do item 8.2., (a), (i), do Plano BM&F.

57. Isso porque, apesar de a renúncia implicar o desligamento dos ex-diretores de seus cargos estatutários, ela não seria suficiente para encerrar todos os vínculos que mantinham com a Companhia, já que todos eles eram também empregados celetistas da BM&F previamente às suas eleições como diretores, como atestam documentos do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, anexados aos autos⁴⁰.

⁴⁰ Doc. SEI 1244943, p. 626 a 630 e p. 637 a 662.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

58. Nesse sentido, a defesa afirma que, com a eleição dos ex-diretores para os seus cargos estatutários, os seus vínculos trabalhistas ficaram suspensos, nos termos da súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho⁴¹. Após a renúncia apresentada, o período de suspensão desses vínculos se encerrou, reestabelecendo-se o contrato de trabalho. É o que explica o Professor Estêvão Mallet, em parecer juntado pela defesa:

*“Como a **suspensão contratual** não implica a perda da condição de empregado, [...] quando cessa o fato que a motiva, a consequência é o pleno reestabelecimento do contrato de trabalho, ante o desaparecimento do fator que apenas impedia a produção de uma parte de seus efeitos.”*⁴² (grifou-se)

59. Ainda de acordo com o parecer do Professor Estêvão Mallet, o vínculo trabalhista apenas se extingue com a adoção dos procedimentos previstos na lei trabalhista, não sendo a renúncia dos diretores de seus cargos estatutários suficiente para encerrá-lo. Em suas palavras:

*“Quem na condição de diretor estatutário, renuncia ao exercício de função diretiva, apenas põe termo a um vínculo jurídico regulado pela Lei n. 6.404/1976 e pelos estatutos sociais da companhia. Não rompe a relação jurídica disciplinada pela CLT. Para o fazer – e sempre poderá fazê-lo, já que o empregado não é obrigado a permanecer no emprego -, terá de observar as disposições legais pertinentes, comunicando o empregador de sua deliberação, inclusive com a concessão do aviso prévio, na forma do art. 487 da CLT, ou, ao menos, com a informação de que não pretende cumprir o prazo correspondente, sujeitando-se ao desconto previsto no §2º do mesmo dispositivo.”*⁴³ (grifou-se)

60. No mesmo sentido, o autor e Professor Mauricio Godinho Delgado aponta como principal efeito da suspensão ao contrato de trabalho “a ampla sustação das recíprocas obrigações contratuais durante o período suspensivo” e, ainda, ressalta a “garantia de retorno do obreiro ao cargo anteriormente ocupado, após desaparecida a causa suspensiva (art. 471, CLT)”⁴⁴.

⁴¹ “O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.”

⁴² Doc. SEI 1245042, p. 2566.

⁴³ Doc. SEI 1245042, p. 2572.

⁴⁴ Delgado, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores — 18. ed.— São Paulo: LTr, 2019, p. 1271.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

61. Dito isto, no caso em tela, os quatro diretores desligados possuíam vínculos trabalhistas anteriores ao processo de desmutualização da BM&F sendo, portanto, seus regimes celetistas de trabalho suspensos apenas quando de suas eleições, e consequente posse, na diretoria da Companhia. Contudo, diante dos pedidos de renúncia, ocorrendo dois deles em 01.07.2008, um em 28.11.2008 e o outro em 01.02.2009⁴⁵, foi retomado o *status quo* celetista inerente à relação de emprego, e seus contratos de trabalho foram rescindidos unilateralmente pela Companhia em 07.07.2008, referentes às renúncias de 01.07.2008, em 08.12.2008, referente à renúncia de 28.11.2008 e em 02.02.2009, referente à renúncia de 01.02.2009.

62. Cumpre ressaltar que tal hipótese também possui entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais trabalhistas no que diz respeito à suspensão do vínculo trabalhista celetista ao empregado que é alçado a diretor de companhia, como é possível depreender das ementas a seguir apresentadas:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. DIRETOR. SÚMULA 269/TST. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. Evidenciado no decisum que a tese de contrariedade à Súmula 269 do TST é razoável, merece ser processado o recurso de revista para melhor exame da matéria. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. DIRETOR. SÚMULA 269/TST. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. O diretor de sociedade anônima, eleito pelos estatutos da sociedade, não tem computado o tempo de serviço no período em que exerce o mandato, pois **na condição de diretor, em razão de eleição, sua destituição fica condicionada às regras do estatuto da sociedade: deixa hibernada a condição de empregado e passa a ser regido, como dito antes, pelo estatuto societário.** Nessa condição, tem o contrato de trabalho suspenso. É precisamente a essa conclusão que se chega pelos fatos narrados no decisum, pois a Corte Regional registra expressamente que o reclamante foi eleito diretor estatutário e na condição de diretor continuou subordinado a outros diretores, integrantes do conselho de administração. Essa particularidade fática revela, em última análise, subordinação às deliberações do órgão colegiado de que participava o reclamante, situação distinta da subordinação inerente ao contrato de trabalho, como entendeu o Tribunal a quo. Contrariedade à Súmula 269 verificada. Recurso

⁴⁵ Doc. SEI 1244943, p. 771-789



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de revista conhecido e provido " (grifou-se) (TST. RR-7590100-54.2003.5.02.0900, 6ª Turma, Relator Ministro Horacio Raymundo de Senna Pires, DEJT 18/09/2009).

“DIRETOR ESTATUTÁRIO. SÚMULA 269, DO TST. **A diretoria de uma S.A. é um órgão da sociedade, e é por meio de seu diretor que a empresa é gerida. Assim, ao ser eleito diretor, o contrato de emprego fica suspenso, pois deixa de ser subordinado à sociedade, para comandá-la.** Se, no entanto, o empregado continuar subordinado à empresa, a designação foi apenas uma forma de mascarar a relação de emprego, desta maneira, o contrato continua em vigor. No mesmo sentido a Sumula 269, do TST.” (grifou-se) (TRT 1ª Região, RO 0101569-83.2017.5.01.0070, 10ª Turma, Relator Juiz Leonardo Dias Borges, DEJT 18/12/2019).

63. Diante disso, me parece que o fato de os ex-diretores terem renunciado aos seus cargos estatutários não caracteriza, por si só, a hipótese prevista no item 8.2., (a), (i), do Plano BM&F (que se refere a **desligamento da Companhia** por vontade própria), já que essa renúncia apenas produziria efeitos em relação ao rompimento dos seus vínculos estatutários, permanecendo, porém, os ex-diretores ainda ligados à Companhia em razão de sua relação de trabalho.

64. Superado esse ponto, passo à análise do segundo e terceiro indícios trazidos pela Acusação. Opto por analisá-los em conjunto uma vez que ambos convergem para a comprovação de um mesmo ponto pela Acusação.

65. Como mencionado acima, após as renúncias apresentadas pelos ex-diretores, a Companhia os demitiu dos seus cargos trabalhistas, sem justa causa, como comprovam os documentos disponíveis nos autos⁴⁶. Quanto a essa situação, a área técnica busca desqualificar essa decisão da Companhia, afirmando que tal demissão ocorreu poucos dias após a renúncia apresentada pelos ex-diretores, bem como que eles não ocuparam cargos na Companhia após a renúncia. Na visão da Acusação, esses elementos corroborariam que a demissão sem justa causa teria sido um artifício para permitir o exercício antecipado dos Direitos de Aquisição de Ações, mas que não representaria, verdadeiramente, um interesse da Companhia de desligar os ex-diretores.

⁴⁶ Doc. SEI 1244943, p. 771-789.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

66. Novamente, me parece que a defesa logrou trazer elementos que contradizem o entendimento da Acusação.

67. De acordo com o esclarecido pela BM&FBovespa na resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 196/13, “[a]s demissões de colaboradores da BM&FBOVESPA realizadas durante o ano de 2008, **inclusive o desligamento dos Beneficiários** [dentre os quais os ex-diretores], **ocorreram no contexto do processo de integração entre BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.** [sic], **que teve como uma de suas etapas a definição da primeira estrutura organizacional da BM&FBOVESPA, que resultou da consolidação das estruturas organizacionais das referidas empresas.** Conforme já salientado acima, o processo de integração entre a BM&F S.A. e a Bovespa Holding S.A. acarretou uma redução de 27% do número de executivos oriundos das duas empresas” (grifou-se)⁴⁷.

68. De fato, como é de conhecimento público, em 08.05.2008, foi aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária⁴⁸, a reestruturação societária que resultou na integração das atividades da BM&F e da Bovespa, com a migração das suas bases acionárias para nova sociedade constituída para essa finalidade específica, a BM&FBovespa. Esse processo de integração, naturalmente, gerou uma sobreposição significativa de funções, atividades e cargos na sociedade resultante da combinação de negócios.

69. Assim, conforme comprovam apresentações feitas ao comitê de integração e ao conselho de administração da BM&FBovespa em junho e agosto de 2008⁴⁹, após a conclusão da reestruturação societária, a Companhia iniciou uma profunda reformulação interna de seus processos, estrutura organizacional e pessoas. Em termos de pessoas, as mudanças afetaram não apenas os cargos de níveis hierárquicos inferiores, mas também a diretoria, que teve uma redução de 44 para 31 executivos. No total, a Companhia previu um desligamento de 300 pessoas, no período de junho de 2008 e abril de 2009⁵⁰.

70. Por conseguinte, essas provas documentais aliadas à explicação da Companhia fornecem, na minha visão, um contraindício relevante à tese acusatória, indicando que o afastamento dos ex-diretores, que ocorreu justamente entre junho de 2008 e fevereiro de

⁴⁷ Doc. SEI 1244943, pp. 687-691.

⁴⁸ Doc. SEI 1244938, pp. 344-348.

⁴⁹ Doc. SEI 1244998, pp. 1446 a 1569.

⁵⁰ Doc. SEI 1244998, pp. 1563.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2009, foi motivado por um interesse legítimo da Companhia de adequar a sua estrutura interna à nova realidade após a reestruturação societária.

71. Aliás, ante as explicações trazidas pela defesa, me parece que os indícios levantados pela Acusação são insuficientes para lançar qualquer dúvida sobre a existência de uma intenção legítima da Companhia de demitir os executivos. Ora, se de fato a decisão de desligamento dos ex-diretores ocorreu como consequência do processo de reestruturação da BM&FBovespa, não é de se estranhar que os executivos não tenham exercido funções na Companhia após a renúncia e tenham sido demitidos dos seus cargos celetistas pouco tempo depois. Afinal, no momento da renúncia, a decisão da Companhia de demitir os ex-diretores já havia sido supostamente tomada, fazendo pouco sentido que eles permanecessem como empregados.

72. Quanto ao quarto elemento de prova trazido pela área técnica, discordo da leitura feita pela Acusação do Plano BM&F.

73. Em relação às hipóteses em que o desligamento ocorreria por vontade do executivo, o Plano BM&F faz menção à renúncia do diretor ao seu cargo, nos seguintes termos: “*se, a qualquer tempo durante a vigência do Plano, o **Beneficiário: (a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego, rescindindo o seu contrato de prestação de serviço, ou renunciando ao seu cargo de administrador: (i) os direitos ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data de seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independente de aviso prévio ou indenização, salvo decisão em, contrário do Conselho de Administração;***” (grifou-se).

74. Entendo que o Plano BM&F faz referência à renúncia por essa ser uma situação em que, via de regra, o desligamento ocorre por vontade do diretor. O aspecto determinante, porém, para aferir se o item 8.2. (a) do Plano BM&F, conforme acima reproduzido, se aplicaria ao caso concreto continua sendo a efetiva existência de vontade do diretor de se desligar da Companhia. Daí porque em uma situação excepcional como a presente, em que a renúncia não implicou, necessariamente, em uma verdadeira manifestação de vontade do diretor de se desligar da BM&FBovespa, não me parece razoável que o item em questão seja aplicado, devendo preponderar a essência do ato.

75. Diferentemente do que alega a Acusação, a meu ver, essa leitura não esvazia o sentido do item 8.2. (a) Plano BM&F. Nas demais situações – que são a grande maioria – em que a renúncia efetivamente signifique uma manifestação de vontade do diretor de se desligar da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

companhia, o referido item do Plano BM&F continua tendo plena aplicação. Ademais, há a possibilidade de existência de diretores estatutários que não tenham vínculo celetista com a sociedade. O que se está reconhecendo neste caso é, apenas, que, em situações excepcionais nas quais se demonstre que o interesse de desligamento era da Companhia e não dos ex-diretores, não faria sentido a aplicação do dispositivo.

76. Portanto, em relação aos ex-diretores A.C.F., M.A.T. e R.M.M., entendo que a Acusação não logrou trazer aos autos um conjunto de indícios suficientes para fundamentar uma conclusão robusta de que tais ex-diretores teriam se desligado da Companhia por vontade própria e não por vontade da BM&FBovespa, e que tal decisão não tenha sido tomada em interesse da Companhia. Nesse sentido, concluo que o Sr. Edemir Pinto deve ser absolvido da acusação de violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, no que se refere à execução dos contratos de opção celebrados com A.C.F., M.A.T. e R.M.M.

77. Passo, então, a analisar o último elemento de prova trazido pela Acusação, que se aplica apenas em relação ao ex-diretor O.Y.. A área técnica entende que o fato de tal ex-diretor ter assumido cargo em autarquia federal logo após o seu afastamento da Companhia demonstraria que o interesse de se desligar teria sido do ex-diretor.

78. Nesse sentido, importante notar que: **(i)** em 11.09.2008, O.Y. foi indicado pelo Presidente da República para compor a diretoria da autarquia; **(ii)** em 10.11.2008 inicia-se no Senado o processo de aprovação da indicação; **(iii)** na ata da reunião do conselho de administração da BM&FBovespa realizada no dia seguinte, é registrada a renúncia de O.Y.; **(iv)** em 26.11.2008, o nome do ex-diretor é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado; **(v)** em 08.12.2008, O.Y. é demitido da Companhia sem justa causa; **(vi)** em 09.12.2008 seu nome é aprovado pela sessão plenária do Senado Federal e **(vii)** em 01.01.2009, O.Y. assume o cargo na autarquia federal.

79. Sobre esse ponto, a defesa argumenta que os eventos acima elencados “*em nada alteram a natureza [do desligamento de O.Y.] [...] da BM&FBovespa, que decorreu de iniciativa desta*”. Para a defesa, acatar a lógica da Acusação corresponderia a admitir que, em todos os casos em que um funcionário é demitido, mas dispõe de outra proposta de ocupação profissional, dever-se-ia considerar que o seu desligamento ocorreu por vontade do empregado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

80. De fato, a cronologia dos eventos me parece um indício relevante de que o desligamento do diretor em questão seria do seu interesse, especialmente considerando a proximidade entre os acontecimentos.

81. Porém, não me parece ser possível concluir, definitivamente, somente com base nessa cronologia de eventos, que o interesse de desligar o ex-diretor não foi da Companhia.

82. Nesse sentido, além dos argumentos trazidos pela defesa e sobretudo dos demais contraindícios acima mencionados, considero relevante o fato de que a decisão de desligamento do vínculo jurídico do Sr. O.Y. com a Companhia, efetivado em 08.12.2008, foi anterior à sua nomeação como diretor da autarquia federal, o que indica certa independência entre esses acontecimentos.

83. Após a aprovação do nome pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o indicado ainda precisa ser aprovado em votação nominal em sessão plenária do Senado Federal, existindo, por reduzida que seja, uma probabilidade de rejeição. No caso concreto, inclusive, a votação foi de 29 votos favoráveis e 16 votos desfavoráveis⁵¹, demonstrando que existe um risco do indicado, seja quem for, não ser aprovado.

84. Em outras palavras, no caso concreto, não me parece possível descartar, com a segurança e robustez necessárias para uma condenação, que a BM&FBovespa tenha tomado a decisão de demitir o diretor e, paralelamente ou posteriormente, tenha surgido a oportunidade de assumir o cargo na autarquia em questão.

85. Entendo que a Acusação poderia ter buscado provas mais específicas para dirimir a dúvida sobre o que de fato ocorreu. Cito, nesse sentido, a possibilidade de requerimento de e-mails trocados com o O.Y. no período em referência, a fim de averiguar eventuais manifestações de interesse de se desligar da Companhia. Na ausência, porém, de outros elementos, considero que a cronologia de eventos acima descrita não consiste em indício grave, preciso e consistente o suficiente para autorizar uma condenação, conforme entendimento consolidado deste Colegiado⁵².

86. Assim, considerando que há dúvida razoável sobre a configuração da conduta ilícita, entendo que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, o Sr. Edemir Pinto

⁵¹ Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/88152/votacoes#votacao_4509

⁵² PAS CVM nº 24/00, j. em 18.08.2005; PAS CVM nº 25/2010, j. em 04.07.2017; PAS CVM nº 05/14, j. em 15.06.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deve ser absolvido da acusação de violação ao disposto no art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 também no que se refere à execução do contrato de opção celebrado com O.Y.

Imprecisões dos critérios utilizados para a determinação do prejuízo imputado

87. Como forma de calcular eventual prejuízo gerado com o exercício das opções, a Acusação apresentou informações detalhadas sobre as quantidades das opções outorgadas, datas de outorga, renúncia e dispensas pela Companhia, bem como preços de exercício das opções e preço de mercado das ações em determinadas datas.

88. Contudo, ao explicar o prejuízo causado pelo exercício antecipado, há imprecisões que prejudicam, a meu ver, o entendimento do caso. Reproduzo abaixo três frases formuladas pela Acusação⁵³ referentes a esse tema:

- (i) *“Para quantificar o **custo para a Companhia**, a não extinção das opções em relação aos quatro beneficiários em questão, e consequente antecipação de seu exercício, resultou em **custo para os acionistas de R\$ 19.901.020,00**, sem que houvesse autorização do CA para esse tipo de despesa.”(grifou-se)*
- (ii) *“Quatro ex-administradores da Companhia renunciaram aos seus cargos de administradores (hipótese prevista no citado regulamento para a extinção de direitos relativos ao Plano BM&F). Porém, além de não terem seus direitos extintos, ainda anteciparam o exercício de suas opções, **o que custou à Companhia R\$19.901.020,00**”.(grifou-se)*
- (iii) *“a. por deixar de exercer devidamente suas atribuições, no intuito de lograr os fins e os interesses da Companhia ao não reconhecer a extinção dos direitos ainda não exercíveis dos ex-diretores que renunciaram, **autorizando pagamentos no valor de R\$ 19.901.020,00** sem submeter o assunto ao Conselho de Administração, como relatado e concluído nos parágrafos 36 a 55 e 98 em violação ao art. 154, caput, da Lei 6.404/1976;” (grifou-se)*

89. Inicialmente, cabe observar que o valor de R\$ 19.901.020,00, apresentado pela Acusação, em decorrência da não extinção das opções em relação aos quatro ex-diretores beneficiários do Plano BM&F, foi calculado com base na multiplicação da quantidade de

⁵³ Parágrafos 54, 100 e 106 (i) (a) do Relatório Nº3/2017 – CVM/SPS/GPS-3, doc. SEI: 1245011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

opções exercidas antecipadamente pela diferença entre o valor da cotação das ações no dia do exercício e o preço de exercício da opção⁵⁴.

90. Refere-se, portanto, à ideia de custo de oportunidade, no sentido de que caso a Companhia não tivesse concedido as antecipações de exercício aos ex-diretores e tivesse ofertado ao mercado a mesma quantidade de ações resultantes dos exercícios das opções que tiveram antecipação de carência, na mesma data em que ocorreu o exercício pelos ex-diretores, a diferença entre o valor que seria virtualmente captado pela companhia e o valor que foi efetivamente por ela recebido pelo exercício das opções, resultaria no montante de R\$ 19,9 milhões.

91. Contudo, ao relacionar este valor de maneira intercambiada com as expressões “custo para os acionistas”, “custo para a Companhia” e “pagamentos autorizados”, entendo que a peça acusatória desconsidera diferenças conceituais e práticas relevantes no que diz respeito ao entendimento dos termos adotados.

92. Considero ser oportuno, portanto, distinguir os três termos anteriormente comentados, de maneira a facilitar a avaliação do caso concreto.

93. Conceitualmente, o *custo para os acionistas* deve ser considerado em função do potencial de diluição acionária decorrente do exercício das opções outorgadas. Do ponto de vista dos acionistas da companhia, o exercício de opções de compra de ações resulta em aumento da base acionária, diminuindo a participação percentual dos demais acionistas.

94. Neste sentido, diluição potencial seria o valor resultante da divisão do número de opções exercidas antecipadamente pelos ex-diretores considerados na Acusação, em relação ao número de ações que compõe o capital social da companhia e que não estejam em tesouraria.

95. Por sua vez, o *custo para a companhia* diz respeito ao reconhecimento, de acordo com o regramento estabelecido pela legislação societária e pelos pronunciamentos e práticas contábeis, dos efeitos do plano de opções nas demonstrações financeiras, especialmente no resultado e no patrimônio da Companhia⁵⁵.

⁵⁴ Doc. SEI 1245011, pág. 83.

⁵⁵ Entende-se aqui, que o conceito amplo de custo contábil, que engloba “custos” e “despesas”. Tecnicamente mais correto seria denominar os efeitos do plano de opções de compra como “despesa”. A doutrina contábil estabelece uma diferenciação entre “custos” e “despesas”. “Teoricamente, a separação é fácil: os gastos relativos ao processo de produção são custos, e os relativos à administração, às vendas e aos financiamentos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

96. Neste sentido, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2008, passaram a apresentar as despesas relacionadas ao plano de opções, por conta da adoção do Pronunciamento Técnico CPC 10, aprovado pela Deliberação CVM nº 562/08, vigente à época da efetivação dos exercícios antecipados⁵⁶.

97. Na nota explicativa 19 das referidas demonstrações financeiras, a Companhia relata sobre o Plano BM&F: *“(c)omo resultado, a Companhia reconheceu como efeito da adoção do CPC 10, o montante de R\$229.519⁵⁷ diretamente contra reservas de lucros em contrapartida de reservas de capital. As despesas relativas a 2008 montaram a R\$25.935.”*

98. De acordo com a mecânica de contabilização das despesas dos planos de opções de compra, o montante a ser reconhecido é determinado na data de outorga, ou seja, *ex-ante* à sua efetiva realização⁵⁸, e seu reconhecimento como despesa no resultado do exercício ocorre ao longo do período de vigência do plano e depende dos fatores associados às condições de *vesting*. Assim, para o cálculo do custo do plano para a Companhia, ou seja, da despesa reconhecida em suas demonstrações financeiras, o valor justo das opções de compra é determinado com base nas características do plano e nas condições do mercado na data da outorga, e não na data de exercício das opções.

são despesas. Na prática, entretanto, uma série de problemas aparece pelo fato de não ser possível a separação de forma clara e objetiva.” (MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos, 11ª edição. Grupo GEN, 2018)

⁵⁶ A outorga inicial do plano ocorreu em 18.12.2007. As datas de carências antecipadas nas outorgas iniciais consideradas foram 19.08.2008, 22.12.2008 e 02.02.2009. Por sua vez, as datas de exercício das outorgas adicionais foram 19.01.2010 e 05.03.2010. Em 16 de dezembro de 2010, a Deliberação CVM 650 aprovou o pronunciamento técnico CPC 10 (R1), versão revisada do CPC 10, e revogou a – revogar a Deliberação CVM nº 562, de 17 de dezembro de 2008.

⁵⁷ Valores em R\$ mil.

⁵⁸ Neste sentido, os itens 10 e 11 do Pronunciamento Técnico CPC 10, aprovado pela Deliberação CVM 562/08 estabelecem: “10. Para transações de pagamento baseadas em ações liquidadas pela entrega de instrumentos patrimoniais, a entidade deve mensurar os produtos ou serviços recebidos e o aumento correspondente no patrimônio líquido de forma direta, pelo valor justo dos produtos ou serviços recebidos, a menos que esse valor não possa ser estimado com confiabilidade. Se for esse o caso, a entidade deve mensurar o valor dos produtos ou serviços recebidos e o correspondente aumento no patrimônio líquido de forma indireta, tomando como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. 11. Para fins de aplicação do item 10, nas transações com empregados e outros prestadores de serviços similares, **a entidade deve mensurar o valor justo dos serviços recebidos com base no valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados uma vez que normalmente não é possível estimar com confiabilidade o valor justo dos serviços recebidos, conforme explicado no item 12. O valor justo desses instrumentos deve ser mensurado na respectiva data de outorga.** Nos itens subsequentes, as referências aos empregados incluem também outros prestadores de serviços similares.” (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

99. Entendo, portanto, que a metodologia utilizada pela Acusação não é adequada para se determinar *o custo para a companhia*, decorrente do exercício antecipado das opções do plano.

100. Finalmente, entende-se por *pagamento autorizado*, o desembolso de caixa associado à liquidação da transação. Contudo, o montante citado pela Acusação não representou o desembolso da Companhia para a liquidação dos contratos de opções.

101. Isto porque, a liquidação do contrato de *stock options* ocorre com a entrega de ações aos beneficiários em troca do recebimento do preço de exercício estipulado contratualmente. A este respeito, os itens 6.2 e 6.2.1 do Plano BM&F estabeleceram: “6.2. O preço de exercício será pago pelos beneficiários nas formas e prazos determinados pelo Conselho de Administração ou pela Comissão (conforme o caso). 6.2.1. Enquanto o preço de exercício não for pago integralmente, as ações adquiridas com o exercício da opção nos termos do Plano não poderão ser alienadas a terceiros, salvo mediante prévia autorização do Conselho de Administração, hipótese em que o produto da venda será destinado prioritariamente para a quitação do débito do Beneficiário para com a Companhia.”

102. Assim, há duas possibilidades para que a companhia liquide o contrato de opção junto ao beneficiário na situação em que ocorre o exercício com liquidação física do contrato de opção de compra.

103. Na primeira hipótese, a companhia realiza aumento de capital, dentro do limite autorizado, com a emissão de novas ações e as utiliza para a liquidação do contrato de opção junto ao beneficiário. Neste caso, a companhia recebe o valor do prêmio pago pelo funcionário e entrega as ações emitidas ao beneficiário, não resultando, portanto, em necessidade de pagamento pela companhia.

104. No caso concreto, conforme registrado em ata da RCA de 18.12.07⁵⁹, foi aprovado por unanimidade um aumento de capital de 7.829.928 ações ordinárias mediante o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano BM&F.

105. Adicionalmente, em ata da RCA de 19.08.2008⁶⁰, foi deliberado por unanimidade de votos e sem ressalvas outro aumento de capital social da Companhia em razão da emissão

⁵⁹ Doc SEI 1244940, p. 541.

⁶⁰ Doc SEI 1244996, p. 1.326



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de 3.216.300 ações ordinárias decorrentes do exercício das opções de compra de ações dos beneficiários do Plano BM&F.

106. Na segunda hipótese de liquidação, a companhia recompra ações em circulação, constituindo saldo de ações em tesouraria, e as utiliza para liquidar o contrato de opções junto ao beneficiário. Neste cenário, há o desembolso pela companhia do valor pago para a aquisição das ações em contrapartida do recebimento do prêmio decorrente do exercício.

107. No caso concreto, as demonstrações financeiras da Companhia para o exercício encerrado em 2009⁶¹ apontam que *“(o) programa de recompra de ações – aprovado em 24 de setembro de 2008 pelo Conselho de Administração e que facultava à Companhia a adquirir até 71.266.281 ações de sua emissão – foi interrompido em fevereiro de 2009 (o Conselho de Administração aprovou o encerramento do programa em maio de 2009). Ao todo foram adquiridas 45.686.000 ações, ao preço médio de R\$5,85”*.

108. Portanto, constatados os fatos apontados nos itens 104, 105, 107 acima, avalio que a metodologia citada nos itens 89 e 90 não tem associação com eventuais pagamentos relacionados ao exercício das opções relacionadas ao Plano, não permitindo reconhecer que houve autorização de pagamentos de R\$ 19,9 milhões relacionados à liquidação dos exercícios antecipados.

109. Portanto, entendo como imprecisos os termos utilizados na peça acusatória, no que diz respeito ao montante relacionado com o *“custo para o acionista”*, *“custo para a companhia”* e *“autorizações de pagamentos”*.

110. Nota-se, contudo, que a caracterização de efetivo prejuízo no valor de R\$ 19,9 milhões não se faz indispensável para a eventual configuração do descumprimento do art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976, de que foi acusado o Sr. Edemir Pinto e que, de todo modo, entendo não ter restado caracterizado.

Os aditamentos aos contratos de opção de compra

111. A segunda conduta supostamente contrária ao interesse social praticada pelo Sr. Edemir Pinto está ligada à celebração, em 30.04.2008, de aditamentos aos contratos de outorga de opção de compra com seis funcionários da BM&FBovespa (*“Beneficiários”*).

⁶¹ Pág. 25 do Relatório de Administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tais aditamentos previram a concessão aos Beneficiários de lote adicional de opções (“Lote Adicional”), nas seguintes condições:

- (i) o prazo de exercício do Lote Adicional seria de 180 dias a contar de 02.01.2010 (item 1.3.); e
- (ii) não se aplicaria ao Lote Adicional “*quaisquer disposições ou decisões tomadas pelo órgão [sic] de administração da BM&F com base no Plano ou do [sic] Contrato, presentes ou futuras, inclusive decorrentes de eventual desligamento do Beneficiário da BM&F, concernentes à antecipação da data de início do prazo para exercício previstas no Plano*” (item 1.2.).

112. Como mencionado acima, o Plano BM&F, por sua vez, previa que:

- (i) as opções de compra outorgadas aos beneficiários observariam “*os seguintes prazos de carência (vesting) para seu exercício: - Data da Concessão: Exercício de 25% (vinte e cinco por cento); - Início do Primeiro Ano – Zero por cento; Início do Segundo ano – Zero por cento; - Início do Terceiro ano - 25% (vinte e cinco por cento); - Início do Quarto ano – 25% (vinte e cinco por cento); e Início do Quinto ano – 25%*” (item 5.1.1.); e
- (ii) se o beneficiário for desligado da Companhia por vontade desta e sem justa causa “*os direitos ainda não exercíveis de acordo com o Contrato de Opção [...] passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência*” (grifou-se).

113. Ante esses fatos, a Acusação entendeu que os aditamentos previram regras diferentes daquelas constantes do Plano BM&F no que se refere ao prazo de carência para o exercício das opções em caso de desligamento dos funcionários por vontade da Companhia e sem justa causa. Isso porque nessa hipótese, de acordo com o referido plano, os Direitos de Aquisição de Ações poderiam ser exercidos imediatamente, enquanto, nos termos dos aditamentos, o exercício das opções que compunham o Lote Adicional apenas poderia ocorrer em 180 dias a partir de 02.01.2010.

114. A defesa, de outro lado, argumenta, primeiramente, que a celebração dos aditamentos “*teve como razão fundamental o interesse na retenção de profissionais-chave para a BM&F*”, visando, ainda, “*manter o alinhamento dos referidos profissionais com o desempenho futuro da Companhia, vinculando-os à expansão, êxito e consecução de seus*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

objetivos [...]”. Ademais, no entendimento da defesa, as condições fixadas nos aditamentos para o exercício do Lote Adicional seriam plenamente compatíveis com o Plano BM&F, uma vez que “não representam nenhum tipo de ônus adicional pela Companhia, em comparação ao estabelecido no Plano BM&F, mas sim uma diferenciação dentro dos limites autorizados por sua Cláusula 4.4.”. Por fim, a defesa ressalta que “todos os atos relacionados ao Plano BM&F, incluindo a celebração dos Aditamentos, foram expressamente ratificados pelos acionistas da Companhia na Assembléia Geral Extraordinária (‘AGE’) realizada em 08.05.2008”.

115. Esse último ponto, que já havia sido suscitado pelo Sr. Edemir Pinto no âmbito do Inquérito Administrativo que deu origem a este PAS, é rebatido pela Acusação que afirma que na assembleia geral extraordinária de 08.05.2008 (“Assembleia de 08.05.2008”) os acionistas apenas teriam ratificado os aditamentos que estivessem de acordo com o Plano BM&F, mas não aqueles que contivessem regras contrárias ao referido plano.

116. Como se vê, há três questões a serem dirimidas no presente caso. Primeiro, se a disciplina estabelecida nos aditamentos referente às condições de exercício do Lote Adicional em caso de desligamento seria incompatível com aquela prevista no Plano BM&F. Segundo, caso se responda positivamente à primeira pergunta, se a fixação de tais condições distintas implicaria em uma violação ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976. Terceiro, se na Assembleia de 08.05.2008 os acionistas teriam de fato ratificado os aditamentos celebrados e, em caso positivo, quais os efeitos que decorreriam dessa ratificação.

117. Passo, na sequência, a enfrentar cada um desses pontos.

Compatibilidade dos aditamentos com o Plano BM&F

118. Quanto ao primeiro ponto, assiste razão à Acusação, na minha visão.

119. De início, é importante ressaltar que a área técnica não questiona a outorga, em si, pelo Diretor Presidente do Lote Adicional aos Beneficiários por meio dos aditamentos, visto que essa possibilidade em tese estava contemplada no item 4.1. do Plano BM&F⁶². O que

⁶² “4.1. Periodicamente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração da Companhia determinará os Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas opções de compra de ações nos termos do Plano, o número de ações que poderão ser adquiridas com o exercício de cada opção, o preço de exercício de cada opção e as condições de seu pagamento, os prazos e condições de exercício de cada opção e quaisquer outras condições relativas a tais opções” (doc. SEI 1244940, p. 532-533)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

se discute, na verdade, são as condições nas quais o Lote Adicional foi concedido, que, segundo a Acusação, seriam diferentes daquelas previstas no Plano BM&F.

120. De fato, enquanto o Plano BM&F previa que, em caso de desligamento do beneficiário por vontade da Companhia e sem justa causa, as opções cujos prazos de carência ainda não tivessem decorrido passariam a ser automaticamente exercíveis antecipando-se o prazo de carência, os aditamentos estabeleciam que o exercício das opções que compunham o Lote Adicional apenas poderia ocorrer em 180 dias a partir de 02.01.2010.

121. Tratam-se de regras claramente distintas. Tanto isso é verdade que as opções objeto do contrato de opção original, disciplinadas de acordo com as regras do Plano BM&F, foram exercidas muito antes daquelas que compunham o Lote Adicional, como se verifica da tabela abaixo⁶³:

	A.C.F.	J.C.B.	M.A.T.	N.L.C.	C.E.S.L.	L.G.M.M.
Data do desligamento	07.07.2008	07.07.2008	07.07.2008	07.07.2008	14.08.2008	14.08.2008
Data do exercício das opções com carência antecipada do Lote Inicial	19.08.2008	19.08.2008	19.08.2008	19.08.2008	19.08.2008	19.08.2008
Data do exercício do Lote Adicional	19.01.2010	18.02.2010	05.03.2010	04.02.2010	23.02.2010	27.04.2010

122. Ademais, considerando que no caso de desligamento sem justa causa, de acordo com o plano, o exercício dos direitos ainda não exercíveis passariam a ser automaticamente exercíveis, a extensão de prazo de exercício verificada na execução do aditamento por conta dos desligamentos, apesar de não causar ônus direto à companhia, resulta em um potencial benefício aos ex-diretores, pois aumenta, em tese, o valor teórico da opção, na medida que há uma associação positiva entre o prazo para o exercício de uma opção de compra e seu valor⁶⁴.

⁶³ Doc. SEI 1244947, pp. 888-915.

⁶⁴ *The probability of large stock prices changes during the remaining life of an option depends on two things: (1) the variance (i.e., volatility) of the stock price per period and (2) the number of periods until the option expires.(...) Given the volatility, you would like to hold an option with a long life ahead of it (large t). Thus,*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

123. Entendo, portanto, que a disciplina prevista no aditamento no que se refere ao prazo de carência para o exercício do Lote Adicional era diferente e incompatível em relação à prevista no Plano BM&F. O argumento trazido pela defesa sobre esse ponto não me convence do contrário.

124. Para a defesa, a concessão do Lote Adicional nos termos previstos nos aditamentos seria autorizada pelo item 4.4 do Plano BM&F, que previa que “[o]s *Contratos de Opção* serão individualmente elaborados para cada Beneficiário, podendo o Conselho de Administração ou a Comissão (conforme o caso) **estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção**, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia, ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que estes se encontrem em situações similares ou idênticas”.

125. Discordo da leitura feita pela defesa desse item do Plano BM&F.

126. A permissão para a customização dos contratos de opção celebrados com os beneficiários referida em tal item não alcança a possibilidade de estabelecer condições diferentes daquelas expressamente previstas no Plano BM&F. E isso por dois motivos.

127. Primeiro porque, nos termos do art. 168, §3º, da Lei nº 6.404/1976, a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados de companhia aberta apenas pode ocorrer “*de acordo com plano aprovado pela assembleia geral*”⁶⁵. Em outras palavras, a lei veda que a concessão aos administradores de opções de compra de ações se dê em condições diversas daquelas previstas em um plano aprovado pela assembleia geral da companhia.

128. Nesse sentido, entender, como sustenta a defesa, que o item 4.4. do Plano BM&F recepciona a possibilidade de celebração de contratos de opção em condições diferentes daquelas previstas no plano aprovado pela unanimidade dos acionistas da BM&F significa conferir ao dispositivo sentido *contra legem* – o que, evidentemente, não pode prevalecer⁶⁶.

the value of an option increases with both the variability of the share and the time to maturity. (Brealey, R. A., Myers (2000). *Principles of Corporate Finance*, 6/e. McGraw-Hill Education, p. 600.)

⁶⁵ Nesse mesmo sentido, a CVM já pontuou, no âmbito do Processo CVM nº RJ2001/8489, j. em 03.01.2002, de relatoria do ex-diretor Marcelo Fernandez Trindade que: “verifica-se, então, que os **requisitos legais para a adoção de um plano de opção de compra de ações** são (i) a previsão estatutária de capital autorizado, (ii) o respeito aos limites desse mesmo capital autorizado; (iii) **a aprovação em assembléia geral**; e (iv) ter o plano como destinatários os ‘*administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle*’.”

⁶⁶ Sobre as regras básicas de interpretação contratual, Paula Forgioni menciona as regras de Pothier: “*Segunda regra: ‘Quando huma clausula he susceptível de dous sentidos, deve entender-se naquele, em que ella póde*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

129. Nesse ponto, é importante lembrar que é perfeitamente legítimo que a assembleia geral fixe apenas balizas gerais em relação aos aspectos mais relevantes que devem ser observados na outorga das opções, conferindo certa discricionariedade à administração para celebrar os contratos de opção, dentro das premissas gerais aprovadas. Havendo, porém, como no presente caso, uma regra clara, objetiva e direta no plano aprovado pela assembleia geral, essa regra não pode ser relativizada pela administração.

130. O segundo motivo pelo qual entendo que o item 4.4. do Plano BM&F não pretendeu autorizar a celebração de contratos de opção em condições distintas daquelas previstas no plano diz respeito à própria interpretação desse dispositivo à luz das demais regras do plano. O item 4.4. deve ser lido, na minha visão, de forma conjugada com o item 4.2. do Plano BM&F⁶⁷, que estabelece os aspectos centrais que deverão ser especificados pelo conselho de administração – ou, no caso, o Diretor Presidente, ao qual foi delegada essa competência – nos contratos de opção celebrados com os beneficiários.

131. Ao permitir a previsão de condições diferenciadas entre cada contrato de opção, entendo que o item 4.4. pretendeu se referir à possibilidade de estabelecer determinadas diferenciações entre os beneficiários em relação a alguma das matérias previstas no item 4.2. – dentre as quais não se inclui a disciplina aplicável às hipóteses de desligamento dos beneficiários.

132. Nessa linha, me parece que seria possível, a partir da leitura dos itens 4.2. e 4.4. do Plano BM&F, que o Diretor Presidente concedesse quantidades diferentes de opções de compra de ações a funcionários que estivessem em um mesmo nível hierárquico. E, de fato, foi isso que se observou na prática, como atestado pela Companhia em resposta ao ofício enviado pela CVM no âmbito do Inquérito Administrativo que deu origem a este PAS, no qual esclareceu que “os funcionários e administradores com maior tempo de permanência na empresa receberam maiores quantidades de ações”, independentemente de seus cargos⁶⁸.

ter efeito; e não naquele, em que não teria efeito algum” (Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação, São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 245)

⁶⁷ “4.2. A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano é realizada mediante a celebração de contratos de outorga de opção entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração ou pela Comissão (conforme o caso): (a) a quantidade de ações objeto da outorga; (b) condições para aquisição do direito ao exercício da opção; (c) prazo final para exercício da opção de compra de ações; e (d) o preço de exercício e condições de pagamento (‘Contrato de Opção’)”.

⁶⁸ Doc. SEI 1245042, p. 2348.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

133. Considero, ainda, relevante fazer uma última observação. Verifico que o item 10.5 do Plano BM&F estabelecia que “o *Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as condições do Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos*”.

134. A legalidade dessa disposição é questionável, ante o que dispõe o art. 168, §3º, da Lei nº 6.404/1976. Mas, mesmo que superado esse ponto, essa disposição tampouco alteraria o meu entendimento.

135. Isso porque, a competência do Sr. Edemir Pinto para celebrar contratos de opção com os beneficiários foi dada pelo conselho de administração da Companhia que, na reunião de 23.10.2007, **(i)** aprovou “**os parâmetros e diretrizes do Plano de Opção de Compra de Ações para funcionários e administradores conforme premissas estabelecidas na AGE da Companhia, realizada em 20.09.2007**”; e **(ii)** ratificou a delegação, ao Diretor Presidente, da competência para “**executar o plano dentro das premissas anteriormente aprovadas, bem como efetuar as outorgas de opção de compra de ações aos beneficiários eleitos nas condições por ele estabelecidas, mediante assinatura dos contratos de outorga de opção com os beneficiários**” (grifou-se).

136. Como se percebe da leitura da ata, não se delegou ao Diretor Presidente todas as competências atribuídas pelo Plano BM&F ao conselho de administração, mas sim, somente, a competência de executar o plano dentro das premissas já aprovadas, outorgando opções de compra aos beneficiários. Nesses termos, não me parece possível a interpretação de que a competência para rever as condições do Plano BM&F, prevista no item 10.5, seria do Sr. Edemir Pinto – de modo que tampouco esse item poderia legitimar a possibilidade de celebração de aditamentos em condições distintas daquelas previstas no Plano BM&F.

Violação ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976

137. Uma vez definido que as condições previstas no aditamento referentes à hipótese de desligamento dos beneficiários por vontade da Companhia e sem justa causa eram incompatíveis com aquelas estabelecida no Plano BM&F, cabe verificar se a celebração dos aditamentos pelo Sr. Edemir Pinto configuraria violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

138. Também nesse ponto, concordo com a posição da Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

139. Como visto acima, o art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 impõe aos administradores que exerçam as suas atribuições buscando sempre atingir os fins e interesses da companhia. Em outras palavras, o atendimento ao interesse social é o que deve guiar todos os atos praticados pelos administradores, que devem privilegiar o interesse da sociedade em relação a quaisquer outros interesses.

140. Normalmente, as acusações por violação ao art. 154, *caput*, têm como “pano de fundo” situações em que o administrador, no exercício de suas atribuições de gestão, pratica um ato supostamente lesivo ao interesse social. O exame desses casos pelo Colegiado da CVM, como ressalta o Presidente Marcelo Barbosa, perpassa “*uma análise da conduta dos administradores, inclusive do conteúdo das decisões tomadas no âmbito dos órgãos colegiados (conselho de administração e diretoria), com o objetivo de aferir se elas se conciliam com o objeto social e os interesses da companhia*”⁶⁹.

141. A tarefa do regulador de analisar se a decisão do administrador seria ou não no interesse da sociedade é sempre bastante complexa. As dificuldades atreladas a essa tarefa decorrem, em larga medida, do fato de que o regulador não está na melhor posição para avaliar qual seria a decisão mais conveniente para a companhia, devendo, por isso, evitar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões negociais⁷⁰. Nessa linha, consolidou-se o entendimento de que, em casos de suposta violação ao art. 154, *caput*, o Colegiado da CVM deve analisar as justificativas trazidas pelo administrador para a realização do negócio, avaliando se elas se amoldam ao interesse social.

142. Neste PAS, porém, me parece que a avaliação do alinhamento do ato praticado pelo Diretor Presidente ao interesse social é relativamente mais simples. Isso porque há no presente processo uma decisão da unanimidade dos acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral extraordinária aprovando os termos do Plano BM&F. E são os acionistas da companhia, que nela investem os seus recursos financeiros, suportando tanto o bônus do

⁶⁹ Manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, no PAS CVM nº RJ2013/11703, de relatoria do diretor Gustavo Borba, j. em 31.07.2018.

⁷⁰ Cf., manifestação de voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez, no PAS CVM nº RJ2013/11703, de relatoria do diretor Gustavo Borba, j. em 31.07.2018: “Com efeito, para que o artigo 154 cumpra com a sua finalidade, a revisão em casos de suspeita de desvio requer um olhar diferente e uma consulta mais abrangente, que busque apurar se atos praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, buscavam de fato atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da companhia. 41. **Essa abrangência deve, contudo, ser delimitada com temperança, sob pena de se transformar uma obrigação de meio em uma de resultado. O caput do artigo 154 não dá ao julgador um poder indiscriminado para rever as decisões dos administradores.** Em especial, não autoriza sindicar se a decisão tomada era a ‘melhor’ ou mesmo a ‘mais adequada’ dentre as possíveis.” (grifou-se)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seu sucesso quando os ônus de seu fracasso, que estão na melhor posição para delimitar os contornos do interesse social⁷¹.

143. Em outras palavras, me parece que a análise pelo julgador do atendimento ao interesse social neste caso independe de um exame do mérito das condições previstas nos aditamentos, como geralmente ocorre nos casos julgados por este Colegiado envolvendo violação ao art. 154, *caput*. No presente PAS, afinal, diferentemente do que se verifica nos precedentes, já há uma definição do que seria, em concreto, o interesse social da Companhia, de modo que cabe ao julgador, apenas, verificar se as condições previstas nos aditamentos eram ou não compatíveis com aquelas aprovadas pela unanimidade dos acionistas da Companhia.

144. Em sendo incompatíveis, entendo que teria o administrador se afastado do interesse social no exercício de suas atribuições, por ter executado atos em condições expressamente diferentes daquelas aprovadas pela unanimidade dos acionistas. Entender diversamente corresponderia a reconhecer que um administrador seria mais legitimado que os acionistas para determinar qual a decisão que melhor se alinharia ao interesse social – o que me parece incongruente com a própria hierarquia entre os órgãos sociais previstas na Lei nº 6.404/1976. Como ressalta Luiz Antonio de Sampaio Campos:

“Esse é o corolário lógico desse princípio. Com efeito, seria um contrassenso que pudesse haver dois interesses sociais e que, nessa situação, de dissenso, prevalecesse a visão dos administradores da companhia, em detrimento da visão do intérprete natural do interesse social, o acionista controlador. Seria o mesmo que a Assembleia Geral deliberasse em um sentido e a administração agisse em outro, sob o pretexto de que teria uma visão diferente do interesse social.” (grifou-se)⁷².

145. À luz de todo o exposto e considerando que, como visto acima, as condições previstas nos aditamentos no que se refere ao prazo para exercício das opções de compra eram distintas daquelas expressamente constantes no Plano BM&F, concluo que o Sr. Edemir Pinto

⁷¹ “Por isto é que se diz que o administrador é dotado de um poder-função, porque o poder lhe é atribuído apenas para realizar o objeto social, atendendo o interesse social. [...] **O juiz primeiro desse interesse social é, na companhia em que haja controle definido, o acionista controlador. É a ele que, em princípio, cabe definir o que é ou deixa de ser do interesse social** [...]” (Luiz Antonio de Sampaio Campos, “Deveres e Responsabilidades” in FILHO, Alfredo Lamy e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 809-811)

⁷² “Deveres e Responsabilidades” in FILHO, Alfredo Lamy e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coords.), *Direito das Companhias*, Rio de Janeiro: Forense, 2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

incorreu em violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 ao celebrar os referidos aditamentos.

146. Os argumentos suscitados pela defesa não alteram o meu entendimento.

147. Primeiro, a defesa alega que a celebração dos aditamentos visou a retenção de profissionais chave na BM&FBovespa, mantendo um alinhamento dos interesses dos referidos profissionais com o desempenho futuro da Companhia. Esse argumento demonstraria, de acordo com a tese da defesa, que a celebração dos aditamentos se deu no melhor interesse da Companhia, não havendo de se cogitar qualquer violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

148. A explicação fornecida pela defesa, a meu ver, é suficiente para justificar porque a outorga, em si, de opções adicionais aos Beneficiários seria compatível com o interesse social, na visão do acusado. Como já referido acima, porém, o que se questiona neste PAS não é a outorga do Lote Adicional, mas sim as condições em que se deu a concessão e execução de tais opções. E, com relação a esse segundo aspecto, não me parece que a explicação da defesa seja suficiente para justificar porque seria no melhor interesse da Companhia a concessão do Lote Adicional em condições diferentes daquelas previstas no Plano BM&F.

149. Isso porque, os aditamentos previam que o exercício das opções do Lote Adicional não poderia ser antecipado nas hipóteses previstas no Plano BM&F, apenas podendo ocorrer em 180 dias a partir de 02.01.2010. Ocorre que, as únicas hipóteses do Plano BM&F em que se previu a antecipação do exercício das opções são referentes a situação que não dependem da vontade do beneficiário – por exemplo, o seu desligamento da companhia por vontade desta. Caso se tratasse de situações que não dependiam da vontade do beneficiário, não me parece que a não antecipação do exercício das opções nessas hipóteses, conforme prevista nos aditamentos, de fato fosse capaz de produzir o efeito de desestimular a saída de profissionais chave da Companhia, como alega a defesa.

150. De todo modo, o fato é que, as explicações fornecidas pelo Diretor Presidente não afastam a configuração do ilícito. Como mencionado acima, não pode o administrador usurpar a competência da assembleia geral e entender que o interesse social seria outro que não aquele expressamente consagrado pela unanimidade dos acionistas. Ao executar o plano de opções de compra aprovado em decisão assemblear em condições distintas dos termos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

originais, tem-se configurada, pelo menos em parte, a desconsideração da autoridade da Assembleia Geral.

151. Em segundo lugar, a defesa argumenta que a execução dos aditamentos não gerou nenhum ônus adicional à Companhia ou prejuízo financeiro, uma vez que, do ponto de vista da BM&FBovespa, os aditamentos alteraram apenas a data em que ocorreria a outorga das opções.

152. Esse argumento, porém, tampouco me convence, uma vez que, em linha com a jurisprudência da CVM, a existência de prejuízo à companhia não é essencial para a configuração do ilícito previsto no art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976⁷³.

153. Entretanto, mesmo tendo em vista que o Sr. Edemir Pinto se afastou do interesse social quando executou os aditamentos em condições diversas daquelas previstas no Plano BM&F, não posso deixar de ponderar, na mensuração da penalidade a ser aplicada, que as novas condições previstas nos aditamentos não impuseram um ônus adicional para a Companhia. Esse fato, a meu ver, reduz significativamente a materialidade da infração e diferencia o presente caso de outros já julgados por este Colegiado.

154. Desse modo, considero que a reduzida materialidade dos efeitos da alteração dos aditamentos para a companhia representa um fator atenuante relevante da conduta do Diretor Presidente, que levarei em conta na dosimetria da pena.

155. Por fim, sem pretender esgotar a discussão sobre o assunto, gostaria fazer uma breve observação.

156. Me parece que se tivesse ocorrido, no caso, violação pelo controlador dos seus deveres no exercício do voto em assembleia geral, a análise do caso seria mais complexa e a solução, possivelmente, outra. Em tal caso hipotético, afinal, em que o controlador não teria agido de acordo com o interesse social, faria pouco sentido a condenação de administrador pelo art. 154, *caput*, por ter celebrado negócio em desacordo com as condições aprovadas, contanto que novas condições fossem do interesse social.

157. O presente processo, porém, em muito se difere dessa situação hipotética, visto que não houve nenhuma alegação de abuso de poder ou de exercício viciado do voto pelos

⁷³ “Entendo que a consumação da violação aos artigos 153 e 154, ‘caput’, da Lei 6.404/76 prescinde de configuração de prejuízo e não acolho a tentativa da defesa em pautar a inépcia da acusação na suposta ausência de prejuízo.” (PAS CVM nº 03/96, de relatoria do diretor Eli Loria, j. em 08.07.2004)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acionistas da BM&F, que aprovaram, por unanimidade, o Plano BM&F na assembleia geral realizada em 20.09.2007.

Suposta ratificação dos aditamentos

158. Por fim, passo a enfrentar a última questão controversa, que diz respeito à suposta ratificação dos aditamentos na Assembleia de 08.05.2008.

159. Esse argumento da defesa tampouco merece prosperar. À luz da redação constante na ata da referida assembleia, não me parece que seja possível afirmar que houve de fato ratificação dos aditamentos. Nesse sentido, a ata registra que unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital do social aprovou:

“(6) (i) a sucessão, pela Companhia, dos contratos de opção celebrados entre a BM&F e os beneficiários do Plano BM&F, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária da BM&F de 20.09.2007, cujos termos e condições são ora ratificados, nos mesmos termos e condições contratados com cada um dos beneficiários que celebraram com a BM&F Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações, cujas cópias encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, aprovando-se, em consequência, a substituição de todas as opções de compra de ações objeto de tais contratos com os beneficiários da BM&F, representando a possível emissão de até 19.226.391 (dezenove milhões, duzentos e vinte e seis mil noventa e uma) ações ordinárias da Companhia, por opções de compra de ações da Nova Bolsa, nos mesmos termos e condições do Plano BM&F, bem como (ii) o novo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (‘Plano’), nos termos do Anevo VI; e”

160. Fica claro, a partir da leitura do trecho acima transcrito, que os acionistas aprovaram a sucessão, pela Companhia, dos contratos de opção celebrados com os beneficiários da BM&F, nos mesmos termos e condições do Plano BM&F – o que, evidentemente, não inclui contratos que foram celebrados em termos distintos daqueles previstos no referido plano, como é o caso dos aditamentos. Me parece, portanto, que a ratificação dos contratos de opção ficou condicionada à obediência dos termos e condições do Plano BM&F, o que não se verificou, como visto acima, em relação aos aditamentos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

161. A defesa alega que seria prova incontestável da ratificação dos aditamentos o fato de que assembleia geral ter aprovado “a possível emissão de até 19.226.391 (dezenove milhões, duzentos e vinte e seis mil e trezentos e noventa e uma) ações ordinárias da Companhia”, o que representava a totalidade das ações decorrente das opções de compra da BM&F existentes à época, incluindo aquelas outorgadas por meio dos aditamentos.

162. Como mencionado acima, não se questiona neste PAS a outorga das opções adicionais em si, mas sim as condições em que se deu tal outorga. Portanto, não me parece que ao aprovar a quantidade de opções outorgadas, inclusive aquelas objeto dos aditamentos, os acionistas teriam também referendado as condições em que a outorga do Lote Adicional se deu.

163. Por todo o exposto, entendo que restou configurada a violação pelo Sr. Edemir Pinto do art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976, no que se refere à celebração e execução de aditamentos aos contratos de opção, em condições diversas daquelas previstas no Plano BM&F aprovado pela assembleia geral.

V. Violação ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976

164. De acordo com o Relatório de Acusação, os membros do conselho de administração da BM&FBovespa foram acusados por não fiscalizarem “o *delegatário para assegurar a obediência ao Plano BM&F*” e, ainda, por não terem implementado “*controles específicos para fiscalizar a execução do Plano BMF e mesmo sendo, em alguns casos, dada ciência direta e inequívoca ao CA da ocorrência de irregularidades, também não houve atuação de seus membros no sentido de corrigir as falhas e melhorar os controles*”⁷⁴, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

165. A defesa, por sua vez, sustenta que, muito embora houvesse controles internos suficientes para fiscalizar a execução do Plano BM&F, à luz dos conceitos à época dos fatos, a decisão sobre a estrutura organizacional da Companhia estaria protegida pelo princípio da *business judgment rule* e, portanto, a CVM não poderia entrar no mérito da decisão dos administradores a respeito da definição da estrutura de controles adotada pela Companhia.

166. Além disso, a defesa afirma que tais controles jamais indicaram a existência de “sinais de alerta” que demandassem investigações, sendo “*desarrazoado esperar que um*

⁷⁴ Doc. SEI 1245011, p. 2084-2085



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

órgão que atua por meio de reuniões periódicas, se envolvesse em toda e qualquer decisão tomada ou ato praticado pelos diretores”⁷⁵.

167. Por fim, a defesa também alega que não houve irregularidades praticadas pelo Sr. Edemir Pinto, tendo em vista que a antecipação do *vesting* dos ex-administradores e a celebração dos Aditamentos estavam de acordo com o disposto no Plano BM&F e, portanto, não havia irregularidades a serem investigadas pelo conselho de administração.

168. Como se vê, no presente caso, pode-se inferir um certo distanciamento entre os membros do conselho de administração e os atos executados, pelo Diretor Geral, no caso da BM&F, e Diretor Presidente, no caso da BM&FBovespa, para a implementação do Plano BM&F. Tal distanciamento consiste em prática comum atualmente, especialmente em companhias de grande porte, onde há delegação de competências, originalmente atribuídas ao conselho de administração ou a diretores, para os seus respectivos subordinados.

169. Observadas as competências legais e estatutárias, não há nada de errado em delegar determinadas funções⁷⁶. São estas delegações que, aliadas a outros fatores, contribuem para o desenvolvimento das companhias. Se assim não o fosse, o crescimento das companhias se limitaria somente às atividades que poderiam ser absorvidas pelo conselho de administração ou pelos diretores estatutários.

170. No entanto, a delegação de determinadas competências não significa que os membros do conselho de administração ou os diretores estatutários, conforme aplicável, deixam de ser responsáveis pelos atos praticados. Assim, na hipótese de os administradores não se envolverem diretamente na execução de determinadas funções, deve-se garantir a existência de controles e mecanismos internos adequados para a fiscalização das atividades da companhia, bem como a sua observância por toda a administração.

171. Tipicamente, a diligência de determinada conduta é examinada sob o aspecto fiscalizatório ou procedimental. No caso mencionado acima, sobressai o aspecto fiscalizatório do dever de diligência⁷⁷, o qual “*abarca dimensão voltada à supervisão das*

⁷⁵ Doc. SEI 1245042, p. 2196.

⁷⁶ As delegações proibitivas são aquelas estabelecidas em função do artigo 139 da Lei das S.A., sendo que, no presente caso, a delegação não configurou quaisquer das hipóteses previstas neste dispositivo.

⁷⁷ No mesmo sentido, o voto do Presidente Marcelo Barbosa: “*Como se sabe, sobressai no dever de diligência seu caráter procedimental, seja naquilo que se relaciona ao domínio negocial, seja no que se relaciona ao aspecto fiscalizatório, mais voltado à supervisão das atividades da companhia. Esta segunda dimensão do dever de diligência passou a ser aferida, especialmente nas últimas décadas, pela existência de procedimentos e controles internos adequados para o monitoramento das atividades da companhia, e sua efetiva observância tanto por membros do conselho de administração (a quem a Lei nº 6.404/1976, em seu art. 142, inciso III,*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mais variadas atividades da companhia, no âmbito da qual a diligência é aferida a partir da verificação da razoabilidade e adequação dos esforços despendidos pelo administrador no desempenho de sua função”⁷⁸⁻⁷⁹. Para tanto, os administradores devem implementar controles internos, que devem ser eficientes para soarem sinais de alerta quando necessário, de forma a assegurar que informações relevantes para o monitoramento das atividades sociais sejam geradas e devidamente utilizadas.

172. Em relação ao aspecto procedimental, a doutrina e a jurisprudência identificaram três ordens de comportamentos que compõem o padrão de diligência e que servem como parâmetro para avaliar a diligência das condutas praticadas pelos administradores, quais sejam, os subdeveres de informar, vigiar e investigar. Para melhor referência, copio a seguinte passagem da manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa⁸⁰:

“Refiro-me, aqui, aos deveres do administrador de se informar, vigiar e investigar, os quais lhe impõem, em linhas gerais, a obrigação de, respectivamente, tomar decisões de maneira informada, monitorar as políticas e atividades da companhia – dirigidas ou fiscalizadas pelo administrador – e tomar adequado conhecimento de fatos quando alertados por circunstâncias que exijam maior atenção sobre determinado assunto”.

atribui expressamente o dever de “fiscalizar a gestão dos diretores”), quanto por diretores. E não poderia ser diferente – afinal, se a lei acionária veda a transferência de competências legalmente previstas de um órgão de administração a outro, ao mesmo tempo seu sistema é, por óbvio, compatível com a estrutura organizacional da grande empresa constituída sob a forma de sociedade anônima. Assim, reconhece a possibilidade de diretores atribuírem funções e formarem uma estrutura administrativa compatível com as demandas de suas respectivas áreas. Isso não significa, como não poderia significar, que deixarão de ser responsáveis pelos atos praticados por seus subordinados” (PAS CVM nº SEI 19957.010904/2018-18, j. em 21.07.2020).

⁷⁸ PAS CVM nº RJ2014/6517, Manifestação de Voto do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 25.09.2019.

⁷⁹ Sobre o aspecto fiscalizatório do dever de diligência, destaco a seguinte passagem de voto proferido pelo então Diretor Otavio Yazbek: “[s]e não por outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também, toda uma dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, à qual não se aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada). (...) Em casos como esse, mais do que uma ênfase no procedimento, a apuração da conduta dos administradores, ao que me parece, deve passar pela análise concreta da forma pela qual se ‘procedimentalizaram’ as atividades dentro da sociedade. Há que se avaliar se os procedimentos criam uma razoável segurança para as atividades da companhia e, para que isto aconteça, é necessário verificar se a ‘procedimentalização’ dos controles internos é razoável e adequada” (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18.02.2013).

⁸⁰ Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.010904/2018-18, j. em 21.07.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

173. A análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência deve ser feita considerando o caráter procedimental do dever de diligência⁸¹. Ou seja, o que deve ser objeto de análise para avaliar o cumprimento de tais subdeveres é a forma segundo a qual o administrador atua ou, conforme aplicável, se os procedimentos internos criam uma razoável segurança para as atividades da companhia. Para que isto aconteça, no entanto, é necessário verificar se o desenho procedimental dos controles internos é suficiente e adequado.

174. Portanto, passo a analisar o procedimento adotado pelos acusados.

175. No presente caso, após a aprovação do Plano BM&F pela assembleia geral, o conselho de administração delegou, observadas as competências previstas na Lei nº 6.404/1976, a execução do Plano BM&F ao Diretor Geral. Ou seja, exceto em relação a determinadas obrigações – tais como, a aprovação do aumento do capital social da Companhia -, o conselho de administração não era obrigado, por lei ou previsão estatutária, a implementar o Plano BM&F.

176. A meu ver, a delegação foi realizada ao Diretor Geral com o objetivo de dar maior celeridade e eficiência ao resultado do Plano BM&F, já que este executivo é, naturalmente, mais próximo dos demais diretores e do dia a dia da companhia. Isso não significa, no entanto, que o Plano BM&F pudesse ser executado de forma discricionária pelo Sr. Edemir Pinto.

177. De fato, a ata da reunião do conselho de administração da BM&F realizada em 23.10.2007⁸² ratifica a autorização concedida ao Diretor Geral para executar o plano dentro das premissas aprovadas.

178. Assim, concordo com o argumento de defesa no sentido de que os membros do conselho de administração não podem e não devem, em benefício do bom andamento das atividades da companhia, se imiscuir em toda e qualquer função desenvolvida pelos seus subordinados, ainda que tal função tenha sido originalmente delegada. Os membros do conselho de administração, assim como os diretores, não podem ser responsáveis – e nem seria razoável – por fiscalizar ato a ato dos executivos da companhia. Desta forma, não se

⁸¹ No mesmo sentido, os seguintes votos: PAS CVM Nº RJ2014/12838, manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 25.06.2019, PAS CVM SEI nº 19957.005981/2016-86, manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, j. em 19.11.2019, PAS CVM Nº RJ2018/8378, j. 21.07.2020.

⁸² Doc. SEI 1244943, p. 606



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pode esperar que tais administradores tenham ciência plena e em tempo real de todas as atividades praticadas nas suas respectivas áreas.

179. No presente caso, ainda que o conselho de administração tenha permanecido responsável pela fiscalização da execução do Plano BM&F, não seria razoável esperar que os acusados revisassem todos os contratos individuais de outorga de opção de compra, tampouco os pedidos para o exercício das opções de compra, exceto na hipótese de ocorrência de sinais de alerta de que o plano não estava sendo executado dentro das premissas aprovadas.

180. Vale lembrar que o Plano BM&F abrangeu mais de 700⁸³ funcionários da Companhia, com a celebração de contratos individuais e termos e condições distintos, observados os respectivos cargos.

181. Portanto, seja pela falta de razoabilidade em razão do volume dos contratos individuais ou pela falta de materialidade em relação às Opções Adicionais, em ambas as situações, não seria razoável esperar que o conselho de administração se debruçasse na revisão de ato a ato, sob pena de desvirtuar as respectivas funções.

182. Além disso, especificamente em relação aos Aditamentos, cabe ressaltar que o que está em discussão não são os Aditamentos em si, dado que a execução do Plano e suas cláusulas já haviam sido aprovadas tanto em assembleia geral extraordinária, quanto por deliberação do conselho de administração. O que se discute é se houve falta de diligência do conselho de administração na fiscalização de aplicação de cláusula do Aditamento distinta ao previsto no Plano BM&F em caso de desligamento do beneficiário por vontade da Companhia e sem justa causa. Enquanto no Plano BM&F as opções cujos prazos de carência ainda não tivessem decorrido passariam a ser automaticamente exercíveis antecipando-se o prazo de carência, os Aditamentos estabeleciam que o exercício das opções que compunham o Lote Adicional apenas poderia ocorrer em 180 dias a partir de 02.01.2010.

183. Todavia, as Opções Adicionais representavam 1,65% do total das opções de compra outorgadas no âmbito do Plano BM&F⁸⁴ sendo, portanto, uma situação singular que não levantava nenhuma “*red flag*” ao conselho de administração. Isto porque, tendo em vista que o Diretor Presidente já possuía autorização necessária para outorgar opções adicionais,

⁸³ Doc SEI 1244947, p. 876-887

⁸⁴ Doc. SEI 1244947, p. 888-925. Calculado pela divisão entre o total de opções concedidas no lote adicional para os seis beneficiários (445.500) pelo número total de opções concedidas pelo plano (27.056.316).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

respeitados os termos e condições originais, a celebração dos Aditamentos não configurava uma informação material para que sujeitasse a revisão e investigação assídua pelo conselho de administração.

184. Dessa maneira, discordo da alegação da acusação⁸⁵ no sentido de que os acusados deveriam estar cientes das supostas irregularidades, já que estavam presentes em todos os eventos que culminaram com a decisão de não extinção das opções de compra.

185. O que acontece é que o conselho de administração não precisa – e nem deve – investigar toda e qualquer informação submetida à sua avaliação. A Lei das S.A. foi criada com base em uma estrutura dualista⁸⁶ da administração, segundo a qual o conselho de administração e a diretoria têm funções distintas: o primeiro com função não corrente, não diária e não ordinária da companhia e o segundo com funções executivas. Para que tal sistema funcione, ambos os órgãos precisam funcionar em harmonia e com confiança recíproca. Assim, a partir do momento que a investigação do conselho de administração se torna excessiva, é possível que as funções de cada órgão se confundam, o que certamente terá influência negativa na organização da companhia⁸⁷.

⁸⁵ Para melhor referência, a Acusação alega o seguinte: “Consoante a tabela 2, observa-se que os membros 1 a 6 do CA estavam presentes na aprovação do Plano BM&F (evento 1), de modo que deveriam conhecer suas regras, já que foram definidos como seus administradores. Estes mesmos membros também estavam presentes na RCA de ratificação da delegação ao Diretor Geral, em 23.10.2007 (evento 2), portanto sabiam da delegação e, por óbvio, de seus deveres de fiscalização inerentes ao exercício de suas funções. Estavam presentes nos eventos 4 e 5, ou seja, foram informados das renúncias de A.C.F. e M.A.T. e do posterior pagamento de ações no exercício de opções destes que, conforme o Plano BM&F, deveriam ter sido extintas. Por fim, também estiveram presentes nos eventos 6 a 9, de modo que foram informados, enquanto membros do CA, sobre as renúncias de O.Y. e R.M., sendo certo que permaneceram no cargo nas datas de seus respectivos pagamentos a título de antecipação das opções ainda não exercidas”. [Doc SEI 1245011, p. 2087].

⁸⁶ Sobre esse assunto, destaco a seguinte passagem do então diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos: “Parece-me importante recordar aqui que a Lei das S.A. adotou claramente uma estrutura dualista da administração, a exemplo do já clássico modelo alemão do *Hafschitrat* e *Vorstand*, e a compreensão dessa estrutura é absolutamente essencial para verificar os deveres e as responsabilidades dos administradores. Porque, como bem reconheceu a Diretora-Relatora, a diretoria tem a função executiva; tem poderes que a doutrina chama de disjuntivos, pois que cada um tem o seu poder individual, não é colegial, embora algumas decisões possam ser objeto de reunião de diretoria, onde também se delibera de forma colegiada. E muitas vezes se exija a assinatura de mais de um diretor para obrigar a companhia” (Inquérito Administrativo CVM Nº TA - RJ2002/1173, j. 02.10.2003).

⁸⁷ Nesse sentido, como bem colocado por Luiz Antonio de Sampaio Campos, “[a] estrutura dualista na administração da companhia não pode ser ignorada, sob pena de afugentar pessoas capazes, honestas e competentes, de aceitarem participar do Conselho de Administração, por conta da eventual extensão dos deveres e responsabilidades dos administradores a excessos utópicos, que tornaria o risco da posição inaceitável à luz das contrapartidas que teriam no exercício do cargo e culminaria por desvirtuar, por completo, a estrutura do Conselho de Administração. Esses preceitos devem pautar a atuação do intérprete e do aplicador da lei” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

186. E aqui reforço que meu entendimento se relaciona com o aspecto procedimental do dever de diligência. A meu ver, a Acusação não logrou êxito em demonstrar que os acusados (i) tomaram decisões de maneira desinformada, (ii) deixaram de monitorar as atividades da Companhia, considerando as respectivas funções do conselho de administração e do Diretor Presidente ou (iii) não tomaram adequado conhecimento dos fatos quando alertados por circunstâncias que exigiam maior atenção sobre o assunto.

187. Adicionalmente, entendo que não havia sinais de alerta que justificariam a exigência de uma fiscalização mais atenta e assídua em relação às outorgas e aos exercícios das opções de compra.

188. Portanto, tendo em vista todas as razões expostas anteriormente, parece-me excessivo, ao ponderar a realidade dos fatos, apená-los por não terem identificado sinais de alerta ou obtido informações adicionais.

189. Em segundo lugar, também entendo que a defesa trouxe elementos suficientes para provar a existência de controles internos na Companhia. E sobre esse ponto, entendo ser importante analisar as condutas dos acusados com razoabilidade, à luz da realidade existente à época⁸⁸.

190. Antes mesmo da aprovação do Plano BM&F, a BM&F S.A. já contava com um comitê de auditoria. Em 2007, tal comitê estava previsto em seu estatuto social e sua composição era de sete membros, sendo quatro independentes.

191. Além disso, a BM&F S.A. também já contava, em 2007, com um Comitê de Indicação e Remuneração (“CIR”). De acordo com os autos, em reunião do conselho de administração da BM&F S.A. realizada em 23.10.2017, formalizou-se a reunião do CIR, realizada em 19.10.2017, de acordo com a qual membros do CIR aprovaram proposta de remuneração dos executivos, inclusive a remuneração com planos de incentivo. De acordo com a ata desta reunião do conselho de administração, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, “a proposta de remuneração da BM&F S.A., proposta pela Comissão de Indicação e Remuneração, conforme documentação encaminhada às pastas dos senhores

Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 798).

⁸⁸ Como bem apontado pelo Presidente Marcelo Barbosa, “a razoabilidade (...) decorre da necessidade de calibrar o alcance esperado com a revisão da atuação dos administradores, especialmente sob a lente da diligência, pelos fatos e circunstâncias relacionados à conduta que se questiona, não cabendo ao julgador exigir do administrador um comportamento extraordinário ou que, na sua visão, entenda ser o ideal” (PAS CVM SEI nº 19957.005981/2016-86, j. 19.11.2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Conselheiros. O C.A. deliberou aprovar em caráter transitório a atual política de remuneração dos executivos. Recomendou, considerando a dinâmica do RH implícita no processo da nova S.A., contratação de consultoria especializada para, se for o caso, propor nova plataforma de remuneração e estímulos, contemplando o aumento da produtividade da empresa”⁸⁹.

192. Tal estrutura permaneceu na BM&F S.A. após a abertura de seu capital. De acordo com o prospecto de oferta pública (“Prospecto”) da BM&F S.A., o conselho de administração e a diretora eram auxiliados pelos seguintes órgãos: “(i) *Comissão de Indicação e Remuneração*; (ii) *Comitê de Auditoria*; (iii) *Comitê de Normas*; (iv) *Conselho Consultivo e Conselho Consultivo Internacional*; (v) *Comitê de Risco*; (vi) *Câmaras e Comissões Consultivas*; (vii) *Comissões Técnicas de Padronização, Classificação e Arbitramento*; e (viii) *Comitê de Ética*.”⁹⁰.

193. Ainda, de acordo com o Prospecto, os comitês de auditoria e de indicação e remuneração da BM&F S.A. tinham as seguintes competências:

(i) Comitê de Auditoria: “o Comitê de Auditoria reporta-se ao nosso Conselho de Administração, competindo-lhe, entre outras matérias: (i) propositura ao Conselho de Administração da indicação dos auditores independentes da Companhia e ratificação da escolha feita, bem como da sua substituição; (ii) acompanhamento dos resultados da nossa auditoria interna, propondo ao Conselho de Administração as ações que forem necessárias para aperfeiçoá-la; (iii) análise do relatório da administração e das nossas demonstrações financeiras, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de Administração; (iv) análise, ao menos trimestralmente, das nossas demonstrações financeiras elaboradas periodicamente; e (v) avaliação da efetividade e da suficiência da estrutura dos nossos controles internos e processos de auditoria interna e independente, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos necessários”⁹¹.

(ii) Comitê de Indicação e Remuneração: “Compete à Comissão de Indicação e de Remuneração, dentre outras funções: (i) seleção e indicação à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração, conforme o caso, de pessoas que, atendidos os

⁸⁹ Doc. SEI 1244943, p. 603.

⁹⁰ Disponível em: <https://www.morganstanley.com.br/prospectos/Prospecto2-1.pdf>. (p. 212).

⁹¹ Disponível em: <https://www.morganstanley.com.br/prospectos/Prospecto2-1.pdf>. (p. 213).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

requisitos legais e aqueles previstos no nosso Estatuto Social, possam ser eleitas para integrar o nosso Conselho de Administração, Conselho de Auto-Regulação, Comitê de Auditoria e Comitê de Normas; e (ii) propositura à Assembléia Geral e ao Conselho de Administração, conforme o caso, dos parâmetros e diretrizes a serem observados na definição da remuneração e demais benefícios a serem atribuídos aos membros do Conselho de Administração, aos diretores, aos membros do Conselho de Auto-Regulação, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Normas”⁹².

194. A referida estrutura não só permaneceu após a criação da BM&FBovespa⁹³, em que os comitês continuaram responsáveis pelas mesmas atividades mencionadas acima, mas também, foi ratificada e reforçada em reunião de conselho de administração⁹⁴, realizada na mesma data, ao aprovar nomes independentes para compor os comitês de auditoria e de indicação e remuneração.

195. Ademais, a defesa trouxe aos autos o relatório de auditoria⁹⁵ elaborado pelo comitê de auditoria da Companhia, em relação ao primeiro semestre de 2008, no qual constavam os resultados das seguintes análises: (i) avaliação de risco da contraparte central, (ii) evolução do projeto de melhoria dos controles internos das áreas contábil e financeira, cujo acompanhamento era de periodicidade mínima mensal, e (iii) elaboração do regimento interno do comitê de auditoria.

196. Além disso, a defesa também trouxe aos autos estudo de assessoria externa contratada pela Companhia, com o objetivo de analisar os principais aspectos da governança corporativa da Companhia e implementar eventuais melhorias durante o ano de 2008⁹⁶. Os órgãos de assessoria aliados a tais estudos, a meu ver, demonstram o cuidado do conselho de administração com o controle das atividades desenvolvidas pela Companhia.

197. Por outro lado, entendo que os esforços empreendidos pelos acusados poderiam ter sido maiores quanto à formalização das discussões em reuniões, dos trabalhos do comitê de indicação e remuneração, bem como do comitê de auditoria.

⁹² Disponível em <https://www.morganstanley.com.br/prospectos/Prospecto2-1.pdf>. (p. 212).

⁹³ Doc. SEI 1244938, p. 344-348.

⁹⁴ Doc. SEI 1245011, p. 2035-2037.

⁹⁵ Doc. SEI 1245082 (Processo Mídias.zip\FI 2237\ Anexo 9)

⁹⁶ Doc. SEI 1245082, (Processo Mídias.zip\FI 2237\ Anexos 11 e 14)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

198. Tais registros poderiam ter conferido maior clareza ao processo decisório, mas, ainda assim, não há nos autos qualquer documento ou informação trazida pela Acusação que demonstre falhas nos mecanismos de controle adotados pelos acusados.

199. Ressalto que a ausência de registro e formalização em atas não é suficiente para provar que os órgãos ou outros mecanismos de controles internos da Companhia não eram suficientes para soarem sinais de alerta em relação à execução do Plano BM&F. Nesse sentido, na minha visão, isso não significa necessariamente que o conselho de administração e os órgãos de assessoria à administração deixaram de cumprir com os seus respectivos trabalhos. Reforço que, para votar pela condenação, é preciso formar convicção firme e clara em relação ao conjunto fático-probatório.

200. E tal fato é de significativa importância especialmente se transportarmos a presente acusação à realidade dos fatos. Muito embora tais órgãos de assessoria sejam consagrados nos estatutos sociais das companhias atualmente, vale lembrar que os fatos ocorreram no período entre 2007 e 2008, quando as Instruções CVM nº 481/09 e 480/09, que foram marcos relevantes para o aprimoramento de divulgação de informações das companhias e de realização de assembleias gerais, ainda não haviam sido editadas.

201. À época dos fatos, vigia a Instrução CVM nº 202/93 que dispunha sobre o registro de companhias para negociações de seus valores mobiliários em bolsa de valores ou no mercado de balcão. Tal instrução se limitava a exigir a divulgação de informações gerais sobre as companhias, não havendo qualquer menção ou obrigatoriedade relacionada aos mecanismos internos de controle⁹⁷.

⁹⁷ Como exemplo, cito o art. sobre divulgação de informações periódicas: “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea “a” deste inciso. II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo; III - edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa; IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea “a” deste inciso. V - sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização; VI - ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido; VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos enviados anteriormente, até dez dias após a alteração; VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

202. Ao final de 2009⁹⁸, tal instrução foi substituída pela Instrução CVM nº 480, a qual passou a exigir a divulgação de informações mais detalhadas sobre a estrutura administrativa das companhias em seu formulário de referência, tais como a divulgação sobre a instalação de comitês de auditoria e alterações de membros em comitês estatutários.

203. Assim, diante de todas essas circunstâncias, avalio como não adequado o entendimento de que a atuação do Conselho de Administração fosse direcionada para itens adicionais à avaliação e monitoramento de assuntos estratégicos e materiais da Companhia, na medida em que outros órgãos instituídos possuíam atribuições diretamente relacionadas ao controle e fiscalização de temas específicos.

204. Portanto, não me parece razoável responsabilizar os acusados por supostamente não terem buscado informações adicionais quando contavam com órgãos de apoio, os quais também não identificaram qualquer irregularidade na condução do Plano BM&F. E, oportunamente, volto a destacar que não seria razoável esperar uma fiscalização tão incisiva tendo em vista o volume dos contratos individuais somados a ausência de materialidade em relação aos Aditamentos e suas respectivas Opções Adicionais.

205. Por fim, antes de concluir, e em linha com precedentes do Colegiado, gostaria de trazer breves orientações aos administradores de companhias abertas, considerando-se os fatos corridos no presente caso.

206. Conforme mencionado acima, eventual infração ao dever de diligência deve ser analisada levando em consideração o seu caráter procedimental. Desta forma, para evitar alegações sobre o descumprimento da diligência, os administradores devem se preocupar em demonstrar que cumpriram com os cuidados do dever de diligência, mediante a formalização de seus atos, observando-se critérios de razoabilidade quanto ao registro de informações proprietárias e sensíveis. Assim, como bem apontado pelo Presidente Marcelo Barbosa⁹⁹:

“A administração deve incluir a manutenção de registros suficientes para que se possa evidenciar as tratativas havidas a respeito de temas relevantes bem como os participantes envolvidos, com a minúcia suficiente para que se permita compreender

acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7º desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior” (disponível em <http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst202.html>).

⁹⁸ Em 07.12.2009.

⁹⁹ PAS CVM SEI nº 19957.005981/2016-86 – Manifestação de Voto, j. em 19.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a evolução dessas discussões, providências consideradas e requeridas, justificativas apresentadas, dentre outros elementos que permitam à própria companhia e, conforme o caso, a terceiros, averiguar a aderência das práticas de gestão e mesmo a aderência das condutas às exigências legais.

Não ignoro, por óbvio, que diversas informações constantes de discussões havidas no âmbito de órgãos de administração apresentam elevado grau de sensibilidade. Portanto, a preocupação externada no parágrafo anterior deve ser entendida com a devida dose de bom senso, de forma que os registros que venham a ser feitos sejam apenas aqueles razoáveis, observado um juízo de necessidade e conveniência. (...)

Dessa forma, e ainda que, pelos motivos expostos anteriormente, entendo que a ausência desses elementos não é suficiente para caracterizar o descumprimento do dever de diligência pelos acusados, aproveito esta oportunidade para reforçar a importância de que as decisões tomadas por administradores de companhias abertas, assim como o processo decisório a elas correspondentes, estejam amparados por documentos e registros consistentes, aptos a demonstrar o cumprimento da diligência adotada pelos administradores, o que, naturalmente, também lhes resguardará na hipótese de revisão posterior dos seus atos, sobretudo em sede de juízo sancionatório”.

207. Portanto, levando-se em conta todos os motivos elencados e associados ao caso concreto, entendo como inadequado imputar responsabilidade aos acusados de violar o art. 153 da Lei nº 6.404/1976 e, portanto, proponho suas absolvições.

VI. Conclusão e dosimetria da pena

208. Diante de todo o exposto aqui e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levei em consideração para a fixação da pena a gravidade das condutas analisadas (que implicam o descumprimento dos deveres fiduciários impostos aos administradores) e o fato de elas serem anteriores à Lei nº 13.506/2017. Além disso, especificamente, no caso do Sr. Edemir Pinto, considerei como circunstância atenuante a falta de evidências de resultados financeiros não esperados em decorrência da execução do plano BM&F, a reduzida materialidade da alteração prevista nos aditamentos, bem como os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

209. Portanto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, proponho:

- (i) a condenação do Sr. Edemir Pinto, na qualidade de Diretor Geral da BM&F e posteriormente como Diretor Presidente da BM&FBovespa, a penalidade de **advertência** pelo descumprimento ao disposto no art. 154, *caput*, da Lei 6.404/1976, ao celebrar e executar aditamentos a contratos de outorga de opção de compra em condições diversas daquelas previstas no Plano BM&F, conforme aprovado em decisão assemblear;
- (ii) a **absolvição** dos Srs. Manoel Felix Cintra Neto, Júlio de Siqueira Carvalho de Araújo, Gustavo Henrique de Barros Franco, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, René Mark Kern e Roberto Rodrigues, na qualidade de membros do conselho de administração, ao disposto no art. 153 da Lei nº 6.404/76 pela ausência de elementos suficientes para caracterizar a atuação sem o devido cuidado e diligência exigidos na fiscalização da atuação do Diretor Presidente.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2021.

Fernando Caio Galdi

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO DFG

(Doc. SEI nº 1367006)

Assina o Voto DFG B3, nos termos do Doc. SEI nº 1367006.

FERNANDO CAIO GALDI

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 14/10/2021, às 18:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1367008** e o código CRC **D3649805**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1367008** and the "Código CRC" **D3649805**.*